

JOSÉ CARLOS COSTA

manuales universitarios

Manual de Derecho Romano Público y Privado

Tercera edición actualizada

 **INCLUYE**
VERSIÓN *eBook*

ABELEDOPERROT



JOSÉ CARLOS COSTA

MANUALES UNIVERSITARIOS

Manual de Derecho Romano Público y Privado

Tercera edición actualizada

© Costa, José Carlos

© de esta edición, AbeledoPerrot S.A., 2016

Tucumán 1471 (C1050AAC) Buenos Aires

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y el autor.

All rights reserved

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the Publisher and the author.

ISBN 978-950-20-2719-7

SAP 41925441

Costa, José Carlos

Manual de derecho romano público y privado / José Carlos Costa. - 3a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2016.

592 p.; 24x17 cm.

ISBN 978-950-20-2719-7

1. Derecho. 2. Teoría General del Derecho. I. Título.

CDD 340.1

JOSÉ CARLOS COSTA

Profesor Regular Titular de Derecho Romano, Universidad de Buenos Aires.

Profesor Ordinario Titular de Derecho Romano, Universidad del Salvador.

Profesor Ordinario Titular de Derecho Romano, USAL - Université Paris I Panthéon - Sorbonne.

Profesor Titular de Derecho Romano, Universidad J. F. Kennedy.

Autor de diversas publicaciones en la especialidad de Derecho Romano en el país y en el extranjero.

INDICE

PORTADA	1
MANUAL DE DERECHO ROMANO PÚBLICO Y PRIVADO	2
PRELIMINARES.	3
INDICE.	3
DEDICATORIA.	4
PALABRAS PRELIMINARES	5
ABREVIATURAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	6
NOCIONES PRELIMINARES	
CAPÍTULO I	7
PRIMERA PARTE - DERECHO PÚBLICO ROMANO	
CAPÍTULO II - DERECHO PÚBLICO ROMANO	13
CAPÍTULO III - PERÍODO MONÁRQUICO	21
CAPÍTULO IV - PERÍODO REPUBLICANO	32
CAPÍTULO V - PERÍODO IMPERIAL	54
CAPÍTULO VI - EL BAJO IMPERIO O DOMINADO	90
CAPÍTULO VII - PERÍODO JUSTINIANO	103
CAPÍTULO VIII - EL DERECHO ROMANO POSJUSTINIANO	112
PARTE SEGUNDA - DERECHO PRIVADO ROMANO	
CAPÍTULO IX - FAMILIA Y PERSONA	122
CAPÍTULO X - EL SUJETO DE DERECHO	130
CAPÍTULO XI - LAS INSTITUCIONES DE GUARDADURÍA DE LOS INCAPACES. LA TUTELA Y LA CURATELA	151
CAPÍTULO XII - LA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL	158
CAPÍTULO XIII - MATRIMONIO	161
CAPÍTULO XIV - LA SUCESIÓN	183
CAPÍTULO XV - LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA	185
CAPÍTULO XVI - LA SUCESIÓN LEGÍTIMA O AB INTESTATO	210
CAPÍTULO XVII - EL NEGOCIO JURÍDICO EN ROMA	219
CAPÍTULO XVIII - EL PATRIMONIO	233
CAPÍTULO XIX - LA POSESIÓN	240
CAPÍTULO XX - LA PROPIEDAD	245
CAPÍTULO XXI - LA SERVIDUMBRE	252
CAPÍTULO XXII - OBLIGACIONES	259
CAPÍTULO XXIII - CONTRATOS	270
CAPÍTULO XXIV - DELITOS	293
PARTE TERCERA - OTROS ASPECTOS DEL DERECHO ROMANO	
CAPÍTULO XXV - PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO	297
CAPÍTULO XXVI - DERECHO PENAL ROMANO	319
CAPÍTULO XXVII - DERECHO ROMANO ADMINISTRATIVO	324
CAPÍTULO XXVIII - EL DERECHO ROMANO Y EL DERECHO ANGLOSAJÓN	327
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	331

Dedicatoria

*Dedico esta edición a mi querida familia,
Isabel, Andrea, Lucas, Romina,
Mateo, Pedro, Juan y Alejandra*

FRANJA
MORADA

PALABRAS PRELIMINARES

A modo de introito debo señalar que además de lo concerniente al derecho público y privado romano he extendido la temática a otros aspectos de éste que habitualmente no son tratados por la doctrina, por cuanto en nuestro país el estudio del derecho romano esencialmente se circunscribe al ámbito del derecho privado. Mas el derecho de Roma constituyó todo el derecho vigente en Occidente y lo abarcó en su totalidad. Por esta razón, y convencido de que debo acercar al alumno el derecho romano en su integridad, he desarrollado también aspectos del derecho constitucional, administrativo y penal romano, siguiendo la tendencia actual de la doctrina europea. También en este último sentido, en cuanto al derecho romano privado, trato en primer lugar el derecho de familia y de la persona, continuando luego con derecho sucesorio romano, apartándome del modo tradicional, en razón de la importancia y gravitación que ha tenido la Familia en el desarrollo de Roma. Finalmente, con el propósito de mantener el espíritu de Justiniano en Institutas, destinado a facilitar el estudio de los estudiantes, he evitado toda referencia de citas en el texto, remitiéndolas a pie de página, para agilizar la lectura y comprensión.

FRANJA
MORADA

ABREVIATURAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tablas	Ley de las XII Tablas
Inst.	Institutas
D.	Digesto
Cód.	Código
Nov.	Novelas
Cód. Teod.	Código Teodosiano
Gayo	Institutas
Ulpiano	Reglas
Tito Livio	Décadas de la Historia de Roma
Cayo Suetonio	Los doce césares
Aulo Gelio	Noches Áticas

FRANJA
MORADA

I. QUÉ SE DEBE ENTENDER POR DERECHO ROMANO

Difieren los autores sobre "qué debe entenderse por derecho romano". Si bien, en general, todos concuerdan en que es el derecho creado por Roma desde su fundación, no coinciden en cuanto a su extensión. Una postura lo estima hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecida en el año 476. Otra, lo hace hasta la compilación de Justiniano, producida entre los años 530 a 534. Finalmente, la que lo considera hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en el año 1453. Los distintos autores exponen razones y fundamentos que avalan el sustento de sus respectivas posturas, las cuales merecen ser respetadas, ya sea que las compartamos o no, porque en ello radica una de las claves del avance del estudio del derecho, el disenso.

Personalmente, entiendo que el derecho romano es "derecho actual". A mi entender, no finaliza, a ultranza, con la última expresión histórica del Imperio Romano en Oriente (año 1453), sino que "continúa" hasta el presente. Nunca lo he concebido de otro modo, así lo he sostenido, defendido y enseñado desde hace tiempo⁽¹⁾.

Acoger cualquiera de las posturas indicadas precedentemente no es camino equivocado si se lo toma tan sólo desde el punto de vista meramente histórico, o como fuente de producción de derecho. Pero lo que significa el derecho romano en sí mismo es algo todavía más profundo, que trasciende lo meramente histórico⁽²⁾. En él radica el numen del derecho del mundo occidental como "claro forjador de las ideas jurídicas a través del paso del tiempo"⁽³⁾. Como casi todas las legislaciones de Occidente abrevan de modo directo, o indirecto, en el derecho romano, entonces mal se lo puede acotar mediante elecciones de hitos históricos. Por el contrario, es menester hallarlo "en el paso" que va más allá de la caída del Imperio Romano de Oriente (año 1453) y "descubrirlo" vigoroso en las instituciones modernas, "transmutado" en derecho actual. Por esta razón sostengo que el derecho romano es "derecho actual", dado que se encuentra en el sustrato de toda disposición legal moderna, especialmente en el derecho privado, y también en el derecho público. Mi convencimiento se nutre al releer a Texeira de Freitas cuando afirma que el derecho romano "es un derecho vivo [...] punto de partida de todo cuanto se ha escrito y se ha de escribir en materia de jurisprudencia"⁽⁴⁾. También en este aspecto resulta indispensable hacer hincapié en que desde hace tiempo el ilustre profesor cordobés Agustín Díaz Bialeto ha acuñado el término "transfusión" cuando refiere a la recepción del derecho romano en la legislación argentina⁽⁵⁾. En la actualidad, el maestro italiano Schipani hace lo propio al referirse al Código de Vélez Sarsfield, afirmando que éste opera "...en modo significativo a una transfusión del derecho romano en Argentina..."⁽⁶⁾.

Por su parte, el maestro italiano Labruna enseña que "se puede intentar aunar los principios que desde el ius de la Roma antigua y a través del derecho común hasta hoy han permanecido vivos a través de la percepción del *aequum et bonum*, es decir, lo justo y lo bueno, que debe substanciar a cualquier ordenamiento que se considere jurídico, que manifieste consecuentemente proporcionalidad en las relaciones entre los individuos y entre éstos y el poder"⁽⁷⁾.

Es por todos estos fundamentos que sostengo que el derecho romano es "derecho actual", por cuanto posee "la suficiente y necesaria operatividad valiosa" que le permite "transmutarse" en las legislaciones modernas en general, y en la nuestra en particular.

En tiempo reciente, me es grato descubrir que el romanista argentino Ghirardi, en su novedosa propuesta sobre la "división de la historia del derecho romano", señala respecto de este último que se trata de "derecho romano actual", y que "está vivo"⁽⁸⁾.

Finalmente, el derecho romano se debe entender desde dos aspectos diversos: el primero, comprendido desde el punto de vista meramente histórico, que es todo el derecho producido desde la fundación de Roma (753 a.C.), manifestado por las distintas fuentes hasta la caída del Imperio Romano de Oriente (año 1453). El segundo, a través de su evolución, recepción, transmutación, en el derecho moderno.

II. DIFERENCIA ENTRE HISTORIA Y DERECHO ROMANO. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE ROMA COMO FUENTE PRODUCTORA DE DERECHO

En consonancia con lo expuesto en el acápite anterior, debo desgarnar sucintamente la diferencia que entiendo existe entre "historia del derecho romano" y "derecho romano en sí mismo". Hablar sólo de la "historia" del derecho romano es "detenernos en el tiempo", y no comprender la importancia que tiene el "derecho de Roma" en la actualidad. Es adoptar, si se quiere, una visión parcializada, acotada, del derecho romano. Es aceptar, que el derecho romano es un derecho perimido, muerto, "que pertenece a lo acontecido", dando razón a los detractores de nuestra asignatura, por cierto en minoría, que pugnan por arrebatarla de los planes de estudio. En cambio, he de dar mérito, y destacar, la importancia que tiene el estudio de la "historia de Roma" como "fuente productora de derecho", puesto que a través de ella se permite analizar e investigar "cómo el derecho es creado" mediante las manifestaciones de las distintas fuentes a lo largo de la historia de Roma.

Ha sido Schipani quien ha dicho que "la romanística italiana contemporánea ha puesto en discusión la denominación 'derecho romano', en el marco de una reflexión encaminada a considerar al Derecho como una realidad integralmente histórica"⁽⁹⁾. Añade también el prestigioso autor, respecto de la necesidad de verificar en las fuentes, "un análisis sobre las condiciones del uso de la denominación ius Romanorum", y que "el profesor Catalano ha puesto en evidencia que hay un valor técnico fijado en esta denominación, la cual ha servido para la elaboración del Derecho hasta Justiniano, y ha demostrado que en las mismas fuentes el concepto de ius Romanorum tiene una función sistemático-histórica de unificación de los iura Romana en devenir expansivo"⁽¹⁰⁾. Finaliza Schipani señalando que "encuentra en la designación ius Romanum la expresión sintética, puntual y operativa que asegura el perfeccionamiento de la construcción de la unidad del sistema de Justiniano; operativa también para unificar el processus de tal iusdespués de Justiniano"⁽¹¹⁾.

Por dicha razón, me ha sido menester dejar en claro mi opinión en cuanto a la diferenciación aludida. El "derecho romano en sí mismo" es más que "la historia de Roma" y sus fuentes de producción, abarcándolas y prolongándolas en el tiempo, subyaciendo transmutado en las legislaciones modernas en general, y en especial en nuestro país.

III. ROMA Y EL MUNDO OCCIDENTAL. PENSAMIENTO JURÍDICO Y DERECHO ROMANO

Hablar de "civilización romana" es hacerlo también en cuanto al "mundo occidental". No se puede concebir una sin el otro. Esto implica una referencia ineludible a "la cultura", entendiéndola como "el grado de madurez de un pueblo". La cultura abarca, entre otras cosas, derecho, lengua, filosofía, historia, política, ciencia, alimentación, usos y modismos sociales, etc. Entonces el derecho no es sino una de las "formas de expresión de cultura". Se puede decir que cuanto más avanzada es la cultura de un pueblo, más profunda es la ciencia del derecho que lo rige, y esto acontece con Roma. La humilde aldea fundada en el año 753 a.C. se erige en la formidable metrópolis del mundo antiguo conocido, dando origen a toda una civilización. Si bien es cierto que Roma no se origina de modo espontáneo sino que metaboliza "el sustrato cultural preexistente en la zona del Lacio", tampoco es menos cierto que su aparición en el mundo antiguo origina la civilización que lleva su nombre, que trasciende el momento histórico y deviene en "mundo occidental"⁽¹²⁾.

En este sentido Labruna señala que "Europa es ante todo un fenómeno cultural. Más que un concepto geográfico es una síntesis de elementos culturales, entre los cuales ocupa un puesto de absoluto relieve el derecho de Roma, la experiencia pública y privada de una comunidad que en la Edad Antigua supo expandirse territorialmente en gran parte del continente, y en vastas áreas de Asia y África. Experiencia constantemente reconocida, luego de la crisis política de esa comunidad, como un patrimonio irrenunciable para el desarrollo ordenado de la vida económica y social de las realidades políticas, muy diferentes entre ellas a causa de su estructura y dimensión, que se constituyeron en Europa en la época intermedia y hasta la edad contemporánea"⁽¹³⁾.

También es bueno recordar la opinión del maestro español Rodríguez-Ennes, quien dice al respecto "aquella gran empresa cultural que, protagonizada por Roma, condujo en suma a la creación de Europa y al sistema de valores propio de la sociedad occidental"⁽¹⁴⁾.

En cuanto al derecho, el mundo romano nos da el mismo y "su pensar". Con esto quiero decir que la "estructura del pensamiento jurídico occidental" es romana. Y digo bien, por cuanto no me refiero tan sólo al período considerado "clásico", que para muchos es el "único genuinamente romano", sino a todo el conjunto de "expresión de Roma", contemplando también su evolución en lo que se conoce como "Imperio Bizantino"⁽¹⁵⁾.

IV. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO PARA LA FORMACIÓN DEL JURISTA

Determinar la importancia que tiene el derecho romano en la formación del jurista contemporáneo es mérito conjunto de toda la comunidad romanista, que de manera unánime se ha preocupado por reafirmar la gravitación que aquél tiene en la preparación intelectual del hombre de derecho.

En este sentido, es bueno recordar las siempre vigentes palabras de D'Ors cuando afirma que "el jurista no debe aplicar su ciencia a una reaccionaria defensa de las viejas formas, sino a una construcción inteligente de las nuevas. Debe esforzarse en dotar el nuevo derecho de una estructura científica. Y para esta función del jurista moderno es de imprescindible utilidad el espíritu del derecho romano. Sólo el conocimiento del derecho romano puede dar al jurista la serenidad necesaria"⁽¹⁶⁾ para lograr su cometido. También en similar tesitura el romanista francés Thomas Yan señala que "hay mucho para aprender del derecho romano y de la tradición romanista, desde el punto de vista general de la transformación occidental de la naturaleza"⁽¹⁷⁾. Por su parte, Ghirardi dice que "cualquier Escuela Superior de Derecho o Facultad que se precie de tal y que pretenda dotar de una sólida formación humanista a sus egresados lo incluye en los planes de estudio"⁽¹⁸⁾.

A mi criterio, la gravitación que tiene el derecho romano en la formación del jurista se logra analizando la cuestión desde dos puntos de vista. El primero, en modo directo, por cuanto surge de las propias manifestaciones vertidas por los profesores en los claustros al destacar la importancia que tiene el derecho romano en la impartición de la currícula. El segundo, indirectamente, se advierte en el campo de la investigación cuando al abordar las distintas instituciones, en especial la normativa argentina y latinoamericana, se descubre su relación con el derecho romano, imponiéndose en el análisis su influencia e incidencia, reafirmando la importancia genética del derecho romano en la creación de la institución en tratamiento, indicando claramente a quiénes está dirigida, y cuál es la fuente esencial de inspiración.

En la Argentina no se puede soslayar la importancia del conocimiento de derecho romano cuando el Código Civil derogado ha sido considerado, junto a su autor Dalmacio Vélez Sarsfield, uno de los más romanistas de Latinoamérica. Incluso, el Código actual mantiene el sesgo romanista contemplando instituciones del derecho romano no previstas en el anterior, v.gr., el derecho de superficie⁽¹⁹⁾. Propiciar lo contrario implica transitar un camino erróneo. En síntesis, puedo decir que "sin el derecho romano, los juristas sabrán el derecho como una lengua nueva, pero nunca lo harán como saber la propia"⁽²⁰⁾.

V. LATINOAMÉRICA Y EL DERECHO ROMANO. TRADICIÓN ROMANISTA EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA. VÉLEZ SARFIELD Y EL ROMANISMO LATINOAMERICANO⁽²¹⁾

Latinoamérica se encuentra impregnada de una fuerte tradición romanista y en algunos casos la presencia del derecho romano es aún más gravitante que en países del Viejo Continente. El derecho romano arriba a Latinoamérica a través de la recepción que de él efectúa la legislación hispánica, es decir, Leyes de Partidas, Nueva y Novísima Recopilación y el Corpus Iuris Civilis utilizado por los juristas de la época. Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil francés, en el año 1804, comienza lo que se conoce como "el sistema de codificación moderno", y el derecho romano es receptado por aquél, por cuanto sus raíces son de marcada influencia romanista. Más tarde, desde el año 1845 en adelante, el Código francés comienza a ser tenido como modelo por la

Al respecto, los maestros Catalano e Schipani, estudiosos profundos de la cuestión, han remarcado constantemente la fuerte influencia del derecho romano en Latinoamérica. Así, Catalano afirma "la existencia de la base sociocultural de la unidad del sistema en un bloque romano ibero-precolombino"⁽²³⁾, y que "el romanismo nunca tuvo solución de continuidad en la América Hispánica ni en el Brasil, más bien ha sido reafirmado con fuerza por los mayores juristas de la Independencia"⁽²⁴⁾. Por su parte, Schipani sostiene que los criterios propios del derecho latinoamericano y de su codificación han desarrollado lo que se llama "perfeccionamiento de la transfusión del derecho romano", porque el sistema jurídico se ha modelado bajo la influencia del sistema romanista⁽²⁵⁾.

En lo que concierne a nuestra legislación, el Código de Vélez es considerado por la doctrina nacional y foránea, uno de los más romanistas de Latinoamérica. Se puede decir que abrevia en la legislación romana, no sólo por la sólida formación jurídica romanista de su autor, sino también por las numerosas citas que lleva a cabo, de fuentes, obras, y autores romanistas, v.gr., Corpus Iuris Civilis, legislación indiana, Códigos de Napoleón, Luisiana, Nápoles; y los doctrinarios Savigny, Ihering, Troplong, Maynz, Zacharie, Pothier, etc.⁽²⁶⁾.

Evidentemente, sin lugar a dudas, Vélez Sarsfield, junto con Augusto Texeira de Freitas⁽²⁷⁾ y Andrés Bello, es uno de los grandes maestros romanistas latinoamericanos, y quien forja "la transmutación del derecho romano en legislación positiva". La magnífica obra de Vélez es prueba harto elocuente de ello. El ilustre romanista cordobés sabe sistematizar en la creación del Código Civil argentino el derecho romano, el derecho español, el derecho patrio y el derecho que le es contemporáneo. Es innegable la influencia que tiene en la obra de Vélez el derecho de Roma. Esto se comprueba a través de su preparación intelectual, evidenciada en sus estudios académicos, en su importante biblioteca personal y, fundamentalmente, en las notas que lleva a cabo en fundamento de su labor legislativa, que, como es sabido, son incorporadas al texto del Código desde la primera edición y mantenidas posteriormente. Las notas del Código Civil constituyen verdadera doctrina que ha dado a conocer el pensamiento jurídico del autor, trasuntando el derecho romano como fuente de inspiración directa, e indirecta, del Código. En el primer caso, mediante citas de la jurisprudencia romana, y en el segundo, a través de citas efectuadas de diversos autores, leyes y códigos de la época de indudable raigambre romanista.

Opino al respecto que toda la obra de Vélez, incluido el Código de Comercio, que creara anteriormente junto con Eduardo Acevedo, y especialmente sus notas del Código Civil, constituyen un reservorio del derecho romano, el paso necesario de este último hacia su concreción en legislación vigente.

El maestro Schipani ha tenido ocasión de decir respecto de la obra de Vélez, que "...El Código, con sus Notas, constituye la expresión más acabada también bajo el perfil teórico de la continuidad existente entre los códigos justinianos y los códigos contemporáneos; lo cual pone de manifiesto, de manera explícita, el papel que tiene la ciencia jurídica y nos guía, con ejemplaridad didáctica, en la estructuración del trabajo científico..."⁽²⁸⁾.

Además, el autor italiano afirma respecto del autor de nuestro Código que "...Dalmacio Vélez Sarsfield, en la América latina independiente, ha continuado este papel de los juristas, como fundador del derecho y como fundador de los códigos. Él ha tomado de los códigos el significado más pleno y más rico, concurriendo en modo significativo a una 'transfusión' del derecho romano en la Argentina, y más generalmente a la construcción del Sistema Jurídico Latinoamericano. Su obra se coloca en un alto nivel, y sobre todo constituye la expresión más evidente de la cadena que vincula la producción de un articulado normativo y el trabajo científico que se encuentra en su base y en el cual se condensa. Las Notas incluyen algunos 'eslabones' de esa cadena..."⁽²⁹⁾.

También Schipani señala ajustadamente que "...Claro es que no se debe hacer un fetiche de estas Notas, sino tener presente el permanente mensaje sobre la naturaleza de los códigos y el trabajo de los juristas. Pero es cierto que, frente a otras interpretaciones acerca de la elaboración y del empleo de los códigos, expresiones éstas del voluntarismo iluminista o del posterior estatal-legalismo en expansión de su época, Vélez Sarsfield, con las Notas puestas en su Código, fija la vía del método de trabajo de los juristas romanos, la naturaleza científica del Código, el papel del jurista, y lo hace más resistente a empleos distorsionados..."⁽³⁰⁾.

En el mismo sentido, el maestro Catalano ha dicho: "...coherente con ello es el espíritu del Código Civil de Vélez Sarsfield y, en particular, el de sus Notas y sus referencias a la 'Ley romana'"⁽³¹⁾.

En este aspecto, el prestigioso romanista Labruna ha dicho que "Dalmacio Vélez Sársfield, uno de los grandes juristas latinos del siglo XIX (práctico, político, profesor, legislador), capaz, aun aquí en la Argentina, de dar vida a un derecho sólidamente consciente de su variado origen, y al mismo tiempo extraordinariamente moderno. El jurista de Córdoba es el que nos ha dado la codificación más romana, por el método más aún por el contenido, también nos demostró la importancia constitucional del derecho romano"⁽³²⁾.

En modo absolutamente coherente con lo expuesto el actual Código Civil y Comercial continúa con la tesitura manteniendo instituciones e incluyendo otras, todas originadas indudablemente en el derecho romano. Los propios "Fundamentos del Anteproyecto" del actual Código Civil y Comercial dejan en claro la influencia e importancia del derecho romano en el derecho argentino, que es mantenida y respetada por sus autores, quienes sostienen a dicho respecto, "existe una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano, este es un cambio relevante, toda vez que la historia revela la extraordinaria influencia de la tradición romana e hispánica, y luego francesa, a partir de la codificación, esta tradición ha sido muy importante durante toda la historia del derecho argentino y la hemos respetado en sus aspectos esenciales". Es evidente la coherencia jurídica de los autores del nuevo Código reconociendo y manteniendo la tradición romanista en el derecho argentino.

VI. SITUACIÓN DEL DERECHO ROMANO EN LA ARGENTINA

El estudio e investigación del derecho romano en el mundo no presenta cortapisa alguna. Europa se encuentra abocada desde siempre al tema, por cuanto el derecho romano es el derecho común para todos los países que forman parte del Viejo Continente⁽³³⁾. Incluso, se ha extendido el estudio y difusión del derecho romano en Rusia, Hungría, Polonia, Rumania, la ex Yugoslavia, y recientemente en Japón y China. En esta última nación, "en colaboración con el Gruppo di ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano, establecido en Roma, se está trabajando en una traducción al chino del Digesto"⁽³⁴⁾.

En nuestro país, la raigambre romanista se mantiene desde larga data, pese a que en los últimos tiempos se ha intentado eliminar la asignatura de algunos planes de estudio. La Universidad de Buenos Aires oferta la materia en lo que se denomina el "Curso Profesional Orientado" (CPO), es decir, de modo obligatorio para aquellos que cursan la orientación en Derecho Privado, pero de modo opcional para los restantes. Esto implica, sin embargo, que un gran número de estudiantes se gradúa sin estudiar derecho romano, haciéndolo sólo de modo referencial, cuando adquieren algunas nociones en otras materias de la currícula. A pesar del fuerte clamor de la comunidad universitaria destinado a que una futura reforma del vigente plan de estudio contemple la ubicación de la materia en su justo lugar, es decir, en el inicio, como base del resto de la carrera, la reciente reforma lo ha mantenido en el "Curso Profesional Orientado"⁽³⁵⁾. No obstante, se advierte al respecto un intento de cambio, por cuanto la introducción de la asignatura "Principios del Derecho Latinoamericano" en la currícula del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, parece dar la razón a esta justa crítica, propiciando el estudio del derecho romano en la fundamentación de los principios rectores de las principales instituciones latinoamericanas.

Las otras universidades nacionales, por el contrario, han mantenido en modo mayoritario la posición tradicional de la materia en el primer año; así, Córdoba, La Plata, Noroeste, Lomas de Zamora, Comahue, Mendoza, y recientemente La Matanza, etc.

La mayoría de las principales universidades privadas han sabido mantener la ubicación tradicional de la materia en primer año, tal es el caso de la Universidad del Salvador en su currícula tradicional, y en la carrera franco-argentina que dicta en coparticipación con La Université Sorbonne-Paris I en nuestro país. Otras universidades que puedo citar son Católica Argentina, J. F. Kennedy, etc.

Los principales romanistas argentinos se encuentran agrupados en la "Asociación de Derecho Romano en la República Argentina", con Secretaría permanente en la ciudad de Córdoba, que organiza la bienal de "Encuentros Nacionales de Profesores de Derecho Romano", que se llevan a cabo en distintos puntos del país desde el año 1977, con la participación entusiasta de gran número de profesores. La mencionada entidad también tiene a su cargo la edición de una Revista de Derecho Romano. Asimismo, la participación de los romanistas argentinos se hace presente activamente en

los "Congresos Nacionales de Derecho Civil", que se llevan a cabo bianualmente a lo largo del país, en donde una de sus "Comisiones" se encuentra reservada exclusivamente al derecho romano; como así también en otros Congresos, Encuentros, Jornadas y Eventos Académicos nacionales.

La producción y calidad de trabajos de los romanistas argentinos en los citados eventos es nutrida y constante, como lo son las múltiples conferencias, cursos y seminarios organizados e impartidos en las distintas universidades nacionales y privadas⁽³⁶⁾.

Entonces, puedo colegir que la tradición romanista en la Argentina se encuentra vigorosa, tal cual surge de los congresos, encuentros, conferencias, cursos de actualización, seminarios, publicaciones, etc., a que he hecho referencia de manera sucinta⁽³⁷⁾.

VII. NOCIÓN DE DERECHO EN ROMA

Una vez efectuada la introducción de la temática respecto a qué debemos entender por derecho romano, su importancia en cuanto a la formación del jurista, y el fundamento que significa para el pensar jurídico del mundo occidental en general, y el latinoamericano en particular, debo circunscribirme, en modo previo y a la vez sucinto, al aspecto de la idea romana del derecho, para luego desarrollar los distintos aspectos que hacen al derecho público y privado romano.

Han discutido largamente los autores en cuanto al concepto del derecho en Roma. Lejos de polemizar, en mi opinión surge siempre clara y vigente la definición de Celso, quien sostiene que derecho es "el arte de lo bueno y lo equitativo" (*ars boni et aequi*)⁽³⁸⁾. La definición de Celso debe ser interpretada en clara referencia al conjunto de preceptos y reglas destinadas a alcanzar el ideal de justicia, y no sólo en relación con la moral, aunque está claro que moral y derecho tienen puntos en contacto, porque en definitiva son un producto social. Los juristas romanos delimitan ambos campos, y en cuanto al derecho, y el logro del ideal de justicia, arriban a ella a través de la noción de equidad (*aequitas*). Debo destacar que en la dirección mencionada hallamos las enseñanzas de Ulpiano, quien señala que justicia (*iustitia*) es la "constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo"⁽³⁹⁾, y la acuñación de los famosos preceptos "vivir honestamente" (*honestae vivere*), "no dañar a otro" (*alterum non laedere*), y "dar a cada uno lo suyo" (*suum cuique tribuere*)⁽⁴⁰⁾. También el pensamiento de Paulo gira en dicho sentido cuando señala que "no todo lo lícito es honesto"⁽⁴¹⁾. Empero, sin perjuicio de lo expuesto, pienso que la jurisprudencia clásica romana entiende el derecho como concreción práctica, desprovisto de abstracciones y teorías, en armoniosa aplicación del conjunto de normas que encuentran fundamento en la equidad.

PRIMERA PARTE - DERECHO PÚBLICO ROMANO

CAPÍTULO II - DERECHO PÚBLICO ROMANO

I. PERÍODO ANTERIOR A LA FUNDACIÓN DE ROMA

No existen en la actualidad fundamentos válidos que permitan determinar el origen y fundación de Roma. Lo cual no aparece como contradictorio ante las excelentes fuentes de su cultura que han llegado a nuestros días, v.gr., historia, literatura, arte, y especialmente el derecho, por cuanto Roma es destruida en distintas oportunidades, perdiéndose en el saqueo del que fuere víctima los vestigios que pudieran brindar certeza a la cuestión. Sin perjuicio de ello, brindaré más adelante fundamentos históricos-científicos que posibiliten una mayor precisión al respecto, sin dejar de lado la versión del registro oral mantenido por la tradición. He de destacar que la cuestión se encuentra en investigación permanente. Esencialmente durante los últimos años se han multiplicado las excavaciones y descubrimientos arqueológicos que tienden a dar mayor precisión al tema⁽¹⁾. En este sentido, es bueno señalar, que todo aquello que se dice hoy, simplemente mañana puede quedar desactualizado ante nuevos descubrimientos.

II. LA SITUACIÓN EN LA PENÍNSULA ITÁLICA

Es evidente que el inicio organizado de Roma como "ciudad-estado" (civitas) no emerge desconectado de la realidad socio-política-cultural de su tiempo. Por tal motivo, es necesario circunscribirme sucintamente al acontecer itálico en el período previo a su fundación. Los estudios arqueológicos y paleontológicos efectuados en la región demuestran desde muy antiguo la existencia en Italia de grupos humanos con vida social intensa que habitan en refugios y grutas desde el paleolítico inferior. Así lo demuestra el poblado hallado en Torrimpietra, en las cercanías de la misma Roma, de cuya excavación se obtienen restos de hogares, chozas, huesos de animales, despojos de comidas, hachas, etc. Luego estas agrupaciones, mejor organizadas en cuanto a orden y defensa, se instalan en otros lugares produciendo asentamientos y caseríos. Para ello es necesario que el grupo social primitivo reconozca el liderazgo de un "jefe" o "padre de familia" (pater familias), quien lo somete a voluntad.

En este sentido es bueno recordar la aguda apreciación del maestro Catalano, siguiendo a Giorgio La Pira, en cuanto sostiene "el carácter constitucional de la familia en el derecho romano⁽²⁾", y su implicancia en el aspecto público y privado, como también las conexiones entre ambos.

Por dicha razón, la familia como "institución política" es prácticamente anterior a la misma configuración de la "ciudad-estado" (civitas). Cada grupo en sí mismo se encuentra bajo la "potestad" de un jefe (pater familiae). El conjunto de distintas familias que reconocen tener un antepasado en común, que de mantenerse vivo los tendría sujetos bajo potestad, recibe el nombre de gens. Sobre esta estructura social del Lacio surge más tarde la "ciudad-estado" (civitas) como organización política. Las familias que se sienten parte de una gens no sólo reconocen un antepasado común, sino que también comparten otras características y modismos, v.gr., habla, dioses, ritos, usos, costumbres, vestimenta, alimentación, territorios, modos de guerrear, etc. Este sustrato cultural primitivo me permito denominarlo mos⁽³⁾.

Esos primeros grupos organizados son de origen indoeuropeo, dedicados a la actividad pastoril, luego conocen la importancia y el valor de los metales (hierro y bronce), que les permite progresar y crecer. La zona del Lacio en particular se encuentra habitada mayormente por la etnia de los latinos, que luego padece una fuerte presión de otros pueblos situados al Norte de origen etrusco, provocando su desplazamiento hacia el Sur.

Con lo expuesto quiero señalar que Roma no surge de la nada, sino que, en definitiva, es el producto de una serie de culturas situadas en la Península Itálica, que convergen, luego, en lo que se da en llamar "civilización romana". En este sentido debo señalar "las culturas prerrománicas" que se extienden a lo largo de la Península Itálica a partir del año 1000 a.C., aproximadamente; así, nurágica, con epicentro en Cerdeña; villanovense, en Bolonia; sítula y ligur⁽⁴⁾, en la región Ovetina; etrusca, en la parte central de Italia y el Mediterráneo Occidental; y sicilia, al sur.

III. LA FUNDACIÓN DE ROMA

He dicho que no se puede precisar con exactitud las causas o acontecimientos históricos que producen el nacimiento de Roma como "ciudad-estado" (civitas), aunque sí es posible conjeturar con cierta precisión sobre ella. No obstante, he de comenzar con la versión de la tradición oral, para luego detenerme y reflexionar sobre otros aspectos que pueden indicarnos su origen basado en fundamentos históricos y científicos. Previo a ello, es necesario mencionar, mínimamente al menos, las otras etnias que se encuentran circundantes en la región del Lacio al momento de la fundación de Roma, tales como: umbros, volscos, sabinos, ecuos, marsos, vestinos, oscos, griegos, samnitas⁽⁵⁾, etruscos⁽⁶⁾, etc.

FRANJA
MORADA

IV. LA LEYENDA

Cuenta esta leyenda que el origen de Roma se remonta al célebre héroe Eneas que huye de la destrucción de Troya, llevada a cabo por los griegos, transportándolo los dioses de dicha ciudad a la zona del Lacio después de padecer incontables peripecias. Instalado en el nuevo lugar, Eneas contrae matrimonio con Lavinia, hija de Latino, rey del Lacio, y descendiente de Hércules. Eneas y Lavinia tienen un hijo llamado Ascanio, quien más tarde funda Alba Longa. Transcurrido el paso del tiempo y habiéndose sucedido diversos reyes de la dinastía fundada por Eneas, se encuentra en el trono Procas, quien antes de morir hace entrega de sus bienes y riquezas a sus hijos Numitor y Amulio, aunque le deja el trono al primero. Amulio, celoso del poder de su hermano, encabeza una sedición y lo destrona, usurpando el trono, y obligando a la única hija de Numitor, llamada Rhea Silvia, a recluirse en un templo como sacerdotisa de la diosa Vesta. No obstante su calidad de virgen vestal, Rhea Silvia se une en secreto con el dios Marte, naciendo de dicha unión dos hijos mellizos, Rómulo y Remo⁽⁷⁾. Amulio, colérico, ordena que ambos niños sean arrojados al río Tíber en una cesta y su madre enterrada viva. Los hermanos se salvan por voluntad de los dioses al ser depositada la canasta en la costa y son rescatados por una loba en las proximidades del Monte Palatino. La loba los amamanta en un principio y luego son protegidos por un pastor de nombre Fáustulo. Cuando ambos hermanos crecen se enteran de su verdadera identidad y derrotan al usurpador Amulio, reponiendo nuevamente en el trono de Alba Longa a su abuelo Numitor. Éste, en recompensa, autoriza a los hermanos a fundar una ciudad sobre el Monte Palatino. Como sólo uno de los dos es quien debe hacerlo, se somete la decisión a la voluntad de los dioses, resultando favorecido Rómulo. En el acto de la fundación, y en circunstancias en que Rómulo se encuentra realizando las ceremonias sagradas que competen a la ciudad, su hermano Remo desafía su autoridad, y el primero lo mata. Refieren las narraciones al respecto que Rómulo se encuentra trazando los límites de la nueva ciudad mediante un surco donde luego se edifican los muros, levantando el arado en los lugares destinados para las puertas, cuando su hermano Remo lo desafía pasando sobre el surco sagrado, recibiendo como castigo la muerte⁽⁸⁾.

La tradición también sostiene que Roma debe su nombre a Rómulo, y que es fundada por éste el 21 de abril del año 753 a.C. Lo cierto es que la Roma actual acepta y festeja esta fecha como la de su fundación⁽⁹⁾.

V. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS SOBRE EL ORIGEN DE ROMA

Señalé en un principio que no se conoce con exactitud cómo se funda Roma. Sólo se pueden aportar distintas conjeturas y posibilidades, más o menos ciertas o creíbles, respecto de su origen, además de la leyenda. En relación con esta última, he de señalar, más allá de su aspecto pintoresco y mítico, que se ha comprobado la existencia de ciertos personajes y ciudades de los cuales habla, como así también del asentamiento de la ciudad primitiva aproximadamente en el siglo VIII a.C.⁽¹⁰⁾.

Desde el punto de vista estrictamente histórico-científico, encontramos distintas posturas que intentan explicar la fundación de Roma, tales como: a) que es fundada por los etruscos, que a su vez también han fundado otras "ciudades-estados" similares en las regiones de Toscana, Bolonia, Milán, Capua, Nola, etc.; b) que el origen es latino y la influencia etrusca es posterior a su fundación; c) que el nacimiento no es distinto al de otras ciudades del Mediterráneo, que aparecen como una evolución sistemática de los asentamientos humanos preexistentes en la región agrupados en gens; d) que su aparición se debe a la necesidad de autodefensa de las gens que habitan la región del Lacio ante un ataque foráneo proveniente de otras etnias del norte de Europa que se desplazan hacia el Sur; etc.

Desde mi punto de vista, todas estas teorías presentan un sustrato científico firme, pero sin que una se imponga sobre las demás. Es por esta razón que anteriormente he señalado respecto de la fundación de Roma que es más preciso hablar de "conjeturas" que de "certezas". Personalmente me inclino desde hace tiempo por la posibilidad de la fundación de Roma como una necesidad de autodefensa regional producida por un grupo de gens que habita el Lacio y que vivencia una emergencia grave en la zona. Para subsistir deciden ceder su soberanía política a favor de la creación de una "ciudad-estado", sometiéndose a las decisiones de sus órganos de gobierno. Me inclino por esta postura en razón de las siguientes consideraciones: 1) La similitud estructural política entre la primitiva ciudad-estado (rey, Senado y comicios) y la gens (jefe de familias, consejo de notables y resto de hombres libres que la componen). 2) La protección jurídica dispuesta en favor del jefe de familias (pater familiae) tal cual un verdadero rey (rex), castigando el atentado contra su vida (parricidium). 3) La vieja atribución de los comicios curiados, que les permite aceptar la creación de una nueva gens en el seno de la comunidad (cooptatio). 4) El sustrato común cultural que poseen mayoritariamente las gens que participan en la fundación de Roma (mos).

VI. EL ORDEN CONSTITUCIONAL ROMANO

Los estudios del derecho romano en nuestro país generalmente se han orientado hacia su influencia y recepción en el derecho privado. Esto es tan así, que casi sin intención se ha dejado de lado en mucho lo concerniente al derecho público. La corriente romanista europea desde hace tiempo ha dirigido los objetivos hacia este aspecto, estudiando la gravitación que el derecho romano tiene en el origen, evolución y recepción de las instituciones de carácter público, sin descuidar, claro está, el derecho privado. Es el caso del derecho constitucional romano. Podemos preguntarnos, entonces, si éste existe. La respuesta es afirmativa. Por supuesto que no tenemos un derecho constitucional romano en sentido moderno, pero sí contamos con "un orden constitucional propio romano", que luego deriva o influencia en el llamado "constitucionalismo moderno" a partir de Montesquieu.

Labruna señala que "hacer historia de la constitución significa tener en cuenta, en el análisis de las estructuras institucionales del derecho público, los factores sociales, económicos, políticos y aun personales o prosopográficos que siempre influyen y determinan la producción de las formas jurídicas. Significa en particular también prestar una atención continua y especialísima a los

problemas que están en lo alto y en lo bajo del derecho entendido como realidad objetiva: los que están en la raíz de las necesidades del mundo subjetivo de la vida y los que resultan de su expansión hacia el mundo del deber ser, es decir, hacia valores que el derecho vehiculiza en la realidad histórica, en primer lugar los de la justicia y la equidad"; y añade también el prestigioso autor que "es necesario volver a proponer con fuerza y convicción a la historia de la constitución romana como tarea específica del romanista contemporáneo, para leer el presente"⁽¹¹⁾.

En mi opinión, si se entiende por Constitución "el modo de expresión política de un pueblo en un momento histórico determinado", es decir "lo que un pueblo organizado quiere ser políticamente", evidentemente Roma ha tenido siempre a lo largo de su acontecer histórico "un orden constitucional", una Constitución. Recordemos, incluso, que esta última no necesariamente debe ser escrita⁽¹²⁾.

El constitucionalismo moderno señala como característica significativa la necesidad de contener una parte formal (política) y otra material (dogmática). Puedo señalar al respecto que el "orden constitucional romano" contempla ambas, por supuesto haciendo la salvedad de que lo formal y lo material no van a estar siempre perfectamente delimitados, pero sí presentando la entidad necesaria que permite individualizarlos. Expondré a continuación los distintos matices que presenta el tema.

1. Aspecto formal del orden constitucional romano

Desde el punto de vista formal, la idea de Estado como "abstracción diferente a la masa de individuos que lo integran" es una creación de los juristas romanos desde antiguo⁽¹³⁾, como así también el carácter coercitivo, burocrático y protagónico del Estado a través de las leyes⁽¹⁴⁾. Incluso Roma, después de su caída, proporciona el modelo político a seguir respecto de lo que se debe entender como Estado en sentido moderno, puesto que el estado romano como expresión política demuestra el equilibrio entre sus diversos órganos para evitar "el abuso del poder", lo que constituye la esencia del moderno sistema constitucional⁽¹⁵⁾.

Es decir, en otras palabras, que Roma proporciona mediante su ejemplo histórico los elementos necesarios básicos que hacen al comienzo del constitucionalismo que más tarde deviene en moderno. Este último limita la acumulación del poder mediante su separación. En Roma, la cuestión presenta otro cariz, por cuanto la característica principal no radica en la separación de poderes, sino en el delicado equilibrio de su pleno ejercicio por parte del órgano político, que al mismo tiempo es ejecutivo, legislativo y judicial. Este mismo sistema romano es el que idea los controles constitucionales necesarios para evitar "el abuso de poder". La experiencia romana, con aciertos y errores incluidos, ha servido inexorablemente al nacimiento del derecho constitucional moderno.

Asimismo, el aspecto formal se manifiesta en los distintos modos de gobierno que se suceden en Roma, comenzando por la monarquía, siguiendo con la república y finalizando con el imperio.

2. Aspecto dogmático del orden constitucional romano

En cuanto al aspecto material, puedo señalar sin hesitar que "el derecho de Roma gira en pos de la defensa del más débil", y en "la equiparación de los postergados en toda situación jurídica que deviene en injusta por dicha causa".

Por supuesto que no se encuentra en la constitución romana una parte programática en el sentido propiciado por el constitucionalismo moderno, pero sí puedo sostener que presenta el aspecto material expuesto. Esto último surge de diversas disposiciones tomadas por los órganos de gobierno a lo largo del acontecer histórico y político de Roma.

En dicho sentido puedo señalar, entre otras consideraciones, las siguientes: la prohibición de la aplicación del derecho de vida y muerte (*ius vitae et necis*) por parte del "padre de familia" a sus hijos sin la opinión del consejo familiar; limitación del abuso de la potestad sobre los hijos,

concediéndoles la emancipación cuando el padre lo vende más de tres veces⁽¹⁶⁾; prohibición de castrar a los esclavos sin justificación válida alguna; prohibición de vender a los esclavos para ser destinados a los espectáculos públicos o para ser arrojados a las fieras⁽¹⁷⁾; disponer la libertad del esclavo cuando el amo lo abandona a su suerte por estar enfermo, queriéndolo recuperar una vez sanado⁽¹⁸⁾; prohibición mediante la sanción de la Lex Poetelia Papiria (326 a.C.) para que una persona libre garantice con su cuerpo la deuda contraída, evitando que caiga en esclavitud si no cumple con el pago estipulado, originando el adagio constitucional moderno que prohíbe la prisión por deuda; facultad del magistrado de ordenar la exhibición de aquel que está injustificadamente retenido (habeas corpus)⁽¹⁹⁾; derecho del ciudadano romano de apelar ante el pueblo reunido en comicios la aplicación de la pena capital (provocatio ad populum)⁽²⁰⁾; derecho de recibir alimentos por parte de los hijos, alcanzando incluso al que está en el vientre materno (nasciturus)⁽²¹⁾; alimentación de la niñez carente dispuesta por los emperadores antoninos⁽²²⁾; considerar libre al nacido de una esclava si tan sólo en algún momento de la concepción ésta goza de libertad⁽²³⁾; inviolabilidad de la propiedad intelectual⁽²⁴⁾; contemplación de la situación jurídica de la mujer hasta lograr que la misma alcance la calidad jurídica de "jefe de familias" (sui iuris)⁽²⁵⁾; equiparación del vínculo de sangre (cognaticio) al civil (agnaticio) y después el desplazamiento del último por el primero⁽²⁶⁾; consideración de carga pública de las designaciones de las tutelas, curatelas, jueces (iudex), árbitros (arbitrator), testigos, etc.;⁽²⁷⁾ prohibición de comerciar con un menor, protegiéndolo de tal modo de su falta de experiencia⁽²⁸⁾; derecho del ciudadano romano de portar un nombre (tria nomina)⁽²⁹⁾, originado esto en la actualidad como atributo de la personalidad; consideración de la importancia del domicilio en la confección del censo ya desde épocas el rey Servio Tulio⁽³⁰⁾, originado ello como atributo moderno de la personalidad; resolución de conflictos mediante modos civilizados, prohibiendo la justicia atávica en mano propia, originando el procedimiento; defensa de la vida en gestación cuando se ordena detener la ejecución de la madre condenada a la pena capital hasta que nazca el hijo concebido⁽³¹⁾; disposiciones sobre edificación y mantenimiento de inmuebles; implementación de la expropiación teniendo en cuenta el bien común y el deber de indemnizar⁽³²⁾; disposiciones sobre seguridad diurna y nocturna de la ciudad; vigilancia de los mercados en cuanto a la calidad y conservación de los productos, incluidos los esclavos⁽³³⁾; derecho a la libertad de tránsito; derecho al voto (ius suffragii)⁽³⁴⁾; derecho del pueblo de exigir rendición de cuenta a los magistrados durante la república⁽³⁵⁾ que también es adoptada por el emperador Diocleciano; obligación de pagar impuestos, someterse al censo y cumplir con el servicio militar bajo pena de ser considerado indigno⁽³⁶⁾; considerar ser humano al que está en el seno materno en modo independiente a la madre (nasciturus)⁽³⁷⁾; derecho a tener sepultura de todo individuo, sea libre o esclavo, considerándola sagrada; libertad de cultos o tolerancia religiosa dispuesta por Constantino en el año 313 mediante el edicto de Milán; etc.

Lo expuesto precedentemente, claro está, es meramente enunciativo, por cuanto la lista es aún más extensa. Con ello he querido demostrar que Roma conoce también el constitucionalismo en sentido material, o dogmático. De la simple lectura de lo antes expuesto se desprende "el sentido humanista y progresista del derecho romano", su meta de "defender al más débil"⁽³⁸⁾, la equiparación de los postergados en el sistema legal primitivo, integrándolos, lo que significa la búsqueda del derecho de igualdad, etc.

Respecto de este tema es bueno tener en cuenta la admirable reflexión efectuada por Labruna cuando sostiene que "en el gran tesoro de la jurisprudencia romana, en la que, se encuentran las raíces de nuestro derecho, la centralidad constitutiva del hombre impone tratar como principio, como la realidad más importante, los estatutos de la persona: los presupuestos, es decir, de la esfera de la capacidad, de una serie abierta de deberes y poderes, de facultades, de obligaciones que ponen al hombre en cuanto tal en el centro del ordenamiento. Estos estatutos dan la medida del derecho, la proporción de las relaciones con los demás hombres y con las cosas. La humanitas como palabra y como concepto es una creación autónoma de los romanos. El valor singular de la persona humana, se ha dicho, obliga al hombre a construir la propia personalidad, a educarse, pero también a respetar y favorecer el desarrollo de la personalidad de los demás. La idea nació y se desarrolló a mediados de la República, cuando Roma se abrió al mundo y a la cultura griega, superando sus primitivos formalismos. Invadiendo todo el derecho y la vida jurídica romana de ese tiempo y en adelante, de un modo 'comprensivo y profundo', en el derecho de familia, en el derecho y el proceso penal, hasta (sobre todo desde la época imperial) en materia de esclavitud, constituyendo un punto cardinal de la gran transformación generada a partir de laaequitas, que caracterizó a la jurisdicción pretoriana y, en consecuencia, a la formación del ius honorarium"⁽³⁹⁾.

En suma, puedo señalar que el orden constitucional romano lo es verdaderamente como tal, presentando un aspecto formal o político, evidenciado en los distintos órdenes de gobierno (monarquía, república, imperio); y un orden material, o dogmático, que tiene siempre en miras la defensa y equiparación del más débil, procurando integrarlo en igualdad. Luego, estas formas

políticas y principios dogmáticos son recepcionados por el constitucionalismo moderno, dándole origen⁽⁴⁰⁾.

VII. DEBIDA CONSIDERACIÓN DEL PERÍODO DE "CRISIS HISTÓRICA"

En modo previo a tratar los diversos períodos políticos que se suceden en Roma, me es menester dejar en claro las siguientes consideraciones para facilitar su entendimiento. Ningún cambio estructural en la historia de Roma se da de manera abrupta. Por el contrario, su resultado es el producto gradual de acontecimientos diversos, que finalizan en la transformación del sistema, matizados con violencia, asesinatos, persecuciones e inestabilidades políticas, etc. Este "período de cambio" he de denominarlo "crisis", que a mi entender significa "transformación", "cambio", "transición".

Las características primordiales de los "períodos de crisis" se manifiestan en la convivencia de estructuras decadentes con otras nuevas, vigorosas, lo cual implica que los "protagonistas activos y pasivos" del momento histórico no son conscientes, por lo general, de que están "participando" de él. Es después, cuando se analizan fríamente los acontecimientos y circunstancias históricas acontecidas, que se determina a la luz de éstos, que "el sistema vigente ha colapsado" y que desemboca en "un sistema político nuevo".

Así acontece a lo largo de la historia de Roma. "El paso de un período político a otro" presenta todas las características de "transición" y "cambio", que "configura un período crítico" y que finaliza en "un sistema político nuevo"⁽⁴¹⁾. Este "período crítico" no siempre presenta la misma extensión de tiempo. Es más, los distintos autores tienen en cuenta diferentes "hitos históricos" para indicar el inicio y fin de cada período en cuestión y suelen polemizar al respecto. Estos "acontecimientos históricos" son "hechos significativos" dentro del período de crisis, a los que cada jurista le otorga una importancia crucial para dar inicio o fin al sistema, v.gr., la dominación etrusca, la creación de la ley de las XII Tablas, las reformas agrarias de los hermanos Graco, la muerte de Julio César, el principado de Augusto, la dinastía Antonina, la tetrarquía, el período bizantino, etc.

La breve referencia expuesta se hace necesaria en razón de estudiar la evolución de la historia de las instituciones de Roma como lo ha sido: "una continuación lógica de vida". Por el contrario, si no nos detenemos en analizar el "período de crisis" sólo se aprecian los sistemas políticos sin continuidad, estancos, autónomos, incausados. En otras palabras, como sistemas que surgen independientemente de la realidad que los produce, dificultando innecesariamente su entendimiento.

Finalmente, el maestro D'Ors ha tenido ocasión de señalar que "además de las consabidas razones de utilidad que se vienen dando para justificar el estudio del derecho romano —valor de antecedente..., de instructor—, para el pensamiento jurídico hay que añadir este otro: utilidad del derecho romano para aleccionarnos sobre cómo hay que actuar en los momentos de transformación jurídica"⁽⁴²⁾.

VIII. DIVISIÓN DE LOS PERÍODOS HISTÓRICOS. FUNDAMENTO DEL CRITERIO ADOPTADO

Sin desconocer, ni tampoco restar méritos a los sistemas adoptados por los grandes estudiosos del derecho romano, tales como, Hernández Tejero, Enrique Ahrens, Eduardo Gibbon, Gustavo Hugo, Pietro Bonfante, Robert Von Mayr, Pietro de Francisci, Álvaro D'Ors, Melchiorre Roberti, Fernández de Buján, Rascón Gracia, etc., he preferido mantenerme dentro de lo que considero el sistema clásico de la división de los períodos históricos, en razón de que es el más conocido y divulgado, con la finalidad de facilitar la comprensión por parte del alumno.

En palabras sencillas, el criterio de división adoptado trae consigo la ventaja de saber de "qué estamos hablando desde un principio", sin la necesidad de establecer comparaciones, bondades y defectos con los otros criterios. De este modo, dado que estamos estudiando esencialmente las

fuentes que producen el derecho romano y no la historia en particular de sus instituciones políticas, me he inclinado por mantener el sistema tradicional, que por otra parte he enseñado y desarrollado en mis clases a lo largo de los años, sin perjuicio de dejar a salvo que pueda llegar a variar la concepción sobre el tema en el futuro.

Por lo demás, en otro orden de consideraciones, creo sinceramente interpretar que el criterio de selección adoptado no es otra cosa que mantener la continuidad de la doctrina romanística argentina mayoritaria, sustentada en lo general, aunque con variedad de pequeños matices, por los primeros profesores de la materia, Raymundo Wilmart⁽⁴³⁾, E. J. Weigel Muñoz⁽⁴⁴⁾ y Horacio H. Dobranich⁽⁴⁵⁾, entre otros. Luego, la misma línea de pensamiento es continuada por los grandes e insuperables maestros, Nelly D. Louzán de Solimano⁽⁴⁶⁾, Humberto Vázquez⁽⁴⁷⁾, Alfredo Di Pietro⁽⁴⁸⁾, Miguel Gallegos García⁽⁴⁹⁾, Alfredo Lapieza Elli⁽⁵⁰⁾, José M. Caramés Ferro⁽⁵¹⁾, Luis Peña Guzmán y Luis R. Argüello⁽⁵²⁾, Mario C. Russomano⁽⁵³⁾ y Nina Ponssa de la Vega de Miguens⁽⁵⁴⁾, entre otros. Debo añadir además en la misma tesitura a los colegas romanistas contemporáneos Juan C. Ghirardi y Juan J. Alba Crespo⁽⁵⁵⁾, Haroldo R. Gabernet y Mario A. Mojer⁽⁵⁶⁾, Irma A. García Netto y Carla V. Amans⁽⁵⁷⁾, Bernardo Nespral⁽⁵⁸⁾, Ricardo D. Rabinovich-Berkman⁽⁵⁹⁾, Andrés E. Guillén⁽⁶⁰⁾, Horacio A. García⁽⁶¹⁾ y Fernando M. Zamora⁽⁶²⁾.

Por lo expuesto, según este criterio, considero en lo personal, la división de la historia de las instituciones políticas de Roma del siguiente modo: Monarquía (753 - 450 a.C.); República (451 - 27 a.C.); Imperio (27 a.C. - 1453 d.C.), con la salvedad de que este último período a su vez se subdivide en Alto Imperio (27 a.C. - 284 d.C.), Bajo Imperio o Dominado (284 - 526), período Justiniano (527 - 565) y período Posjustiniano (567 - 1453).

Debo señalar, con el ánimo de no caer en una involuntaria contradicción, que el considerar como fin del Imperio Romano el año 1453 lo es tan sólo como referencia meramente histórica, por cuanto a lo que a derecho romano se refiere he dejado ut supraprofectamente en claro mi posición fundada acerca de que éste es "derecho actual". A su vez, entre cada uno de los períodos señalados, emerge el "tiempo de crisis", que se origina con la decadencia de un sistema político y su consolidación en uno nuevo, indicando en cada caso las particularidades que trae consigo. Por su parte, en cada período histórico he de indicar cuáles son, a mi juicio, las principales fuentes de producción que originan el derecho romano que se encuentra vigente trasmutado en las legislaciones actuales.

IX. NUEVA PROPUESTA RESPECTO DE LAS FUENTES DE PRODUCCIÓN DEL DERECHO ROMANO

Ha sido larga mi meditación respecto del criterio a adoptar en lo referente al presente acápite. La doctrina romanista ha vertido por lo general su opinión, ya sea mediante estudios generales de la cuestión para fundar la elección de alguno de los criterios sustentados, o aportando uno nuevo es el caso, entre otros, de Bonfante, Alvaro D'Ors, Gibbons, Hernández Tejero, De Francisci, Schipani, etc. Todos ellos han contribuido, por demás, independientemente de los criterios adoptados, en beneficio del derecho romano. No se puede señalar cuál de los criterios sustentados es más o menos apropiado que otro. En definitiva, la elección de una clasificación o criterio no es otra cosa que una evaluación doctrinaria personal destinada a lograr una mejor comprensión y enseñanza del derecho romano en procura de fijar su grandeza, importancia y actualidad.

Por mi parte, después de estudiar detenidamente los fundamentos de los distintos criterios, comprendiendo y aceptando la importancia y seriedad de todos ellos, me he permitido aportar mi propia idea respecto del tema.

En mi opinión, el análisis y enseñanza de los "períodos históricos" de Roma debe efectuarse de acuerdo con la capacidad de "producir derecho", es decir, determinar las "fuentes de derecho" preponderantes en cada período. La meta, en principio, claro está, es la obra cumbre de Justiniano, el Corpus Iuris Civile, por cuanto el mismo es punto de arribo y partida del derecho del mundo occidental. Todo el derecho producido por Roma desde su fundación es recopilado en esta magnífica obra, aun con desaciertos, permitiendo el mantenimiento del derecho romano y su despegue hacia el derecho moderno.

En este sentido es bueno recordar a D'Ors, cuando enseña la importancia que "la consideración del desarrollo histórico del derecho romano nos suministra para el diagnóstico de la crisis y la confianza que pueda darnos para su superación"⁽⁶³⁾.

De tal modo, me permito dividir la "evolución de las fuentes de producción del derecho romano" en dos etapas perfectamente diferenciadas: la primera, desde la fundación de Roma (753 a.C.) hasta la creación del Corpus Iuris Civile de Justiniano (530-534); y la segunda, desde la entrada en vigencia de este último hasta la actualidad.

La primera etapa he de denominarla "producción del derecho romano" y guarda estrecha vinculación con los "períodos históricos de Roma" y la "creatividad del derecho". Analizando la evolución de esto último hasta la recopilación justiniana, considero que la "producción del derecho romano" se logra fundamentalmente mediante tres etapas, que denomino "quietud", "dinámica" y "estática".

La segunda etapa, que he dado en llamar "resurgir del derecho romano", se encuentra vinculada a la "supervivencia", "transfusión", "trasvasamiento", "transmutación", "transfiguración", del derecho romano operado tras la recopilación justiniana, originando el derecho actual del mundo occidental. Es decir que el derecho romano se encuentra "vivo", "vigente", en las codificaciones y legislaciones modernas. Dicho de otra manera: "el derecho actual" no es otra cosa que "derecho romano transfigurado" en aquél. Comprende tres períodos, que denomino "sobrevivencia", "renacimiento" y "transfiguración". A continuación desarrollaré los criterios mencionados.

1. En cuanto a la etapa primera, "producción del derecho romano", he de señalar en particular respecto de sus divisiones lo siguiente:

El período de "Quietud" abarca desde la fundación de Roma (753 a.C.) hasta la creación de "la ley de las XII Tablas" (451 a.C.), en la cual prima el derecho oral, es decir, la costumbre. El derecho se encuentra entonces inserto dentro del sustrato cultural general de la primitiva etapa fundacional de Roma, denominada específicamente "costumbre jurídica de los antepasados" (mores maiorum), que es resguardado, interpretado y aplicado por la casta sacerdotal, fiel exponente de la clase patricia, la más poderosa e influyente.

El período de "Dinámica" comprende desde la creación de la "ley de las XII Tablas" (451 a.C.) hasta la sanción del "Edicto Perpetuo de Salvio Juliano" (118 d.C.). Tiene intensa relación con la labor asombrosa del pretor, ejercida en modo paralelo y vinculada con el "derecho quiritaro", originando "el derecho honorario", que suaviza, adecua, modela, el excesivo rigorismo del primero mediante la creación de "acciones" que enriquecen el derecho de Roma.

El período de "Estática" se extiende desde el "Edicto Perpetuo de Salvio Juliano" (118) hasta la creación del Corpus Iuris Civile (530-534). Se caracteriza por la pérdida paulatina de la espontaneidad creativa del pretor, y el encauzamiento lento e inexorable hacia el camino de la compilación. El primer vestigio al respecto es la decisión de Adriano al ordenar la recopilación del "Edicto del Pretor", a cargo del eximio jurista de la época Salvio Juliano. La "producción del derecho" comienza a perder "dinámica" para pasar a la "estática" de las recopilaciones. Es ahora el poder del Emperador, la autoridad del Estado, fundamentalmente el encargado de crear derecho.

2. Refiriéndome a la etapa del "resurgir del derecho romano", sus divisiones, en modo singular, son las siguientes:

El período de "Sobrevivencia" es el tramo comprendido entre la compilación justiniana (530-534) y la "Escuela de Bolonia" o "Escuela de los Glosadores" (principios del siglo XII), en el cual el derecho romano "supervive" en diversas recopilaciones, manteniendo "la identidad valiosa que lo caracteriza".

El período de "Renacimiento" abarca desde la "Escuela de Bolonia" hasta la sanción del "Código de Napoleón" (1804), considerado el primer código en sentido técnico moderno, tomado como modelo por los códigos que aparecen a posteriori. El derecho romano renace con toda la pujanza de sus instituciones, forjando las bases del derecho contemporáneo.

El período de "Transfiguración" comprende desde la creación del "Código de Napoleón" (1804) hasta la actualidad. En este período el derecho romano se encuentra "transmutado" en las codificaciones modernas. Éstas no son otra cosa que "derecho romano vigente actualizado a las necesidades del mundo moderno".

Capítulo III - Período Monárquico

CAPÍTULO III - PERÍODO MONÁRQUICO(1)

I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA(2)

La Roma primitiva no es ajena a la configuración de las "ciudades-estados" (civitas) de su tiempo, constando, por ende, de tres órganos de gobierno básicos, Rey, Senado y Comicios.

1. El rey (rex)

Es el jefe político, religioso, militar y judicial de la "ciudad-estado". Su poder no es despótico o absoluto, sino, por el contrario, es el representante de la comunidad y se comporta como tal. En dicho sentido, es bueno señalar que el rey en Roma es "rey de los romanos" (rex romanorum) y no rey de Roma (rex romae). La figura política del rey es la de representar a la comunidad. Es el ciudadano al cual el pueblo le confiere la atribución de representarlo y dirigirlo.

La monarquía romana presenta las siguientes características: única, vitalicia e irresponsable. Es única por cuanto sólo un ciudadano es nominado rey, no siendo colegiado el cargo. Es vitalicia, porque una vez designado, el rey ocupa el cargo hasta su muerte. Es irresponsable, como consecuencia directa de la duración vitalicia, dado que por esta razón nunca responde por sus actos de gobierno.

Es bueno adelantar a este respecto que justamente los caracteres que presenta el rey son opuestos a los que más tarde tienen los magistrados republicanos que lo reemplazan, a saber, pluralidad, periodicidad y responsabilidad. Este cambio opera como consecuencia de los excesos cometidos por la dinastía de los etruscos, con el fin de evitarlos en el futuro.

La monarquía romana no es necesariamente hereditaria, sino que el rey en ejercicio "designa" a su sucesor, que puede o no ser descendiente suyo. Esto último, en mi opinión, tiene el objetivo de favorecer políticamente al rey, en el sentido de que tenga la libertad para designar sucesor libremente según las necesidades de la comunidad, eligiendo al mejor, pudiendo incluso tejer alianzas con las distintas familias poderosas y no encontrarse sujeto únicamente a la suya.

Debo destacar que éste es, en rigor de verdad, el verdadero sistema sucesorio político legal romano de gobierno a lo largo de su historia, dejando a salvo el período republicano. Durante la Monarquía y el Imperio, es el rey, príncipe o emperador quien por lo general designa a su sucesor, que no necesariamente debe ser descendiente suyo.

El rey tiene las siguientes atribuciones: 1. Políticas. Dirige junto con sus colaboradores la "ciudad-estado", dicta leyes, representa a la ciudad, preside el senado, celebra tratados y administra el tesoro público. 2. Militares. Ejerce la jefatura del ejército, tiene a su cargo la defensa de la ciudad, declara la iniciación y el fin de la guerra. 3. Religiosas. Posee la atribución de dirigir el culto público, dicta e interpreta leyes al respecto, y sanciona a quienes las infringen. Los distintos colegios sacerdotales, augures, feciales y flamines, son verdaderos auxiliares dependientes de su poder. 4. Judiciales. Por revestir el cargo de Supremo Sacerdote, tiene la atribución de interpretar (interpretario) leyes y costumbres (mores maiorum), castigar penalmente a quien comete un delito y dirimir los conflictos suscitados entre los distintos "jefes de familia" de manera pacífica, ya sea en forma directa o a través de la designación de árbitros.

2. El Senado (Senatus)

Es un cuerpo consultivo del rey que nace prácticamente con la misma fundación de Roma. Es la asamblea de los "jefes de familia" (pater familiae), que tiene y ejerce gran poder en la vida política de Roma.

En mi opinión, considero al Senado, con sus virtudes y defectos incluidos, como la verdadera columna vertebral de la organización política romana, dado que siempre se encuentra presente en la vida institucional de Roma. Advierto que si bien cambia con el tiempo la configuración conductiva de la comunidad organizada, virando de la monarquía a la república, y luego más tarde al imperio, el Senado se mantiene siempre inserto políticamente en la organización constitucional romana, ejerciendo verdadero poder e influencia, tornándose en verdadero factor ineludible de gobierno durante todo el desarrollo de la historia de Roma.

En cuanto a sus atribuciones, el Senado posee las siguientes: asesora al rey y a sus funcionarios; presta conformidad a las decisiones comiciales (auctoritas patrum) y ejerce la reyecía interina (interrex).

3. Los comicios (comitia)

Es la asamblea deliberativa más antigua del pueblo romano. Etimológicamente significa "reunión" (com ire). Todos los ciudadanos romanos tienen participación activa en ellos. La diferencia sustancial con el Senado consiste en que éste sólo se encuentra conformado por los "padres de familia", mientras que los comicios están integrados por todos los ciudadanos romanos, sean o no "jefes de familia". El único tipo de comicio existente en el período monárquico es el "comicio por curias", denominado precisamente "curiado". La palabra "curia" significa "reunión de viriles" (co viria), es decir, "reunión de varones o ciudadanos romanos". La "curia" consiste en una subdivisión "política-administrativa-religiosa" de la ciudadanía romana.

Destaco que resulta un poco confuso determinar con precisión el origen de la "curia", por cuanto se remonta a la fundación misma de la ciudad, época escasa en fundamentos históricos y fértil en leyendas. Por dicha razón, tradicionalmente se dice que la ciudad (civitas) en sus comienzos es dividida por Rómulo teniendo en cuenta la composición étnica de su población en tres "tribus", latinos (ramnes), sabinos (titienses) y etruscos (luceres). También, a su vez, Rómulo subdivide cada "tribu" en diez "curias"⁽⁴⁾, totalizando treinta en total. Al frente de cada una de éstas se encuentra un jefe (curio), que obedece a su vez a un único jefe superior (curio maximus).

Las deliberaciones y votaciones se llevan a cabo mediante el voto de cada "curia" en particular, que discute primero la cuestión en privado dirigida por el curio, luego éste es portavoz de la decisión final ante el curio maximus, y el pueblo en pleno reunido en comicio. La votación se define por simple mayoría, lo que significa que se logra mediante el voto a favor de dieciséis "curias".

Los comicios tienen las siguientes atribuciones, a saber: consultan los auspicios para elegir rey; invisten a este último de sus poderes mediante la "ley curiada del imperio" (lex curiata de imperio); intervienen en la otorgación de los testamentos (comitia calata); participan en la adopción política de un "padre de familia" por otro "padre de familia" (adrogatio) y suministran tropas para la defensa de la ciudad.

Puedo afirmar que durante el período monárquico los comicios curiados carecen de facultades legislativas propiamente dichas.

II. CRONOLOGÍA DE LOS REYES DE ROMA⁽⁴⁾

Se considera tradicionalmente que el período monárquico es protagonizado por siete reyes que, en orden cronológico, son los siguientes⁽⁵⁾.

1. Rómulo

De origen latino. Funda Roma en el año 753 a.C. Se le atribuye la creación de las primeras instituciones políticas. Entra en guerra con sus vecinos sabinos, arrebatando a sus mujeres, ocasionando lo que la leyenda conoce como el famoso "rapto de las sabinas", firmando más tarde la paz que origina la fusión entre ambos pueblos.

2. Numa Pompilio

De origen sabino. Se dedica a organizar la primitiva actividad religiosa. Reforma el calendario. Manda edificar el templo de los dioses Saturno y Jano.

3. Tulio Hostilio

De origen sabino. Durante su gobierno se produce el famoso combate de que da cuenta la leyenda entre los Horacios, tres hermanos de origen romano, y los Curiacios, tres hermanos de origen albano, resultando vencedores los primeros, originando como consecuencia la destrucción de la ciudad de Alba Longa. También ordena la construcción de la "Sede del Senado" (Curia Hostilia). Respecto de Tulio Hostilio, puedo decir que es el primero que adopta decisiones de marcado signo social, por cuanto se le atribuye la distribución de tierras entre los ciudadanos que no las poseen, haciéndolo posiblemente para descomprimir una ya incipiente presión social por parte de los plebeyos.

4. Anco Marcio

De origen sabino. Extiende el territorio de Roma hasta el mar, erigiendo el puerto de Ostia en la desembocadura del río Tíber. Ordena la construcción de un puente de madera que une la ciudad primitiva con la fortaleza del monte Janículo.

5. Tarquino Prisco "el Antiguo"

De origen etrusco, aunque se llama Prisco, se lo conoce como "el Antiguo" para diferenciarlo del último rey llamado también Tarquino. Governa entre los años 616 y 579 a.C. Construye la cloaca máxima de la ciudad que permite aliviar la situación del terreno pantanoso ubicado en la depresión conocida como "Velabre", situada entre el Palatino y el Capitolio, en la zona del Foro. Ordena levantar un circo público para celebrar las fiestas y el templo dedicado al dios Júpiter.

6. Servio Tulio

Tradicionalmente se señala que su origen es etrusco, aunque se discute esto último, puesto que parte de la misma tradición sostiene que es latino de nacimiento, y que Tarquino Prisco lo adopta y hace casar con su hija Tanaquil, convirtiéndolo en yerno. Governa entre los años 578 y 534 a.C. Construye el recinto conocido como Septimontium. Se le atribuye, aunque es motivo de discusión, la autoría de la trascendental reforma de carácter "político-social" que incluye la creación de los "comicios centuriados", "tribados" y la acuñación de la primera moneda.

7. Tarquino "el Soberbio"

También de origen etrusco. Governa entre los años 534 y 519 a.C. Es el último rey de Roma. Se le atribuye la construcción del templo del Capitolio y el drenaje del Foro Romano a través del trazado de la cloaca máxima. Durante su reinado acontece la precipitación de la caída de la monarquía y el comienzo del paso a la república. La leyenda cuenta que este monarca es un tirano cruel y que los excesos cometidos en su gobierno, especialmente la violación de Lucrecia, esposa de su primo Tarquino Colatino por parte de su hijo Sexto, origina el levantamiento del pueblo y la caída de la monarquía.

FRANJA
MORADA

III. ORGANIZACIÓN SOCIAL⁽⁶⁾

1. Los patricios (patricii)

Es la clase social por excelencia de la Roma primitiva, la más poderosa, la que posee y monopoliza todos los atributos políticos y la riqueza. Se considera miembros de la misma a todos los descendientes de las familias fundadoras de la ciudad. El patriciado constituye la ciudadanía romana, y por ende goza en exclusividad de todos los derechos públicos y privados que le son inherentes.

2. Los plebeyos (plebeii)

Es el resto de la población, compuesta por todos los hombres libres, excluidos los patricios. En origen son pequeños propietarios, comerciantes, artesanos, labradores, operarios, etc. Cumplen con el servicio militar, votan en los comicios y sólo tienen acceso a la propiedad de insignificantes parcelas de tierra destinadas al cultivo, lo cual motiva la inevitable lucha de clases con los patricios hasta lograr la equiparación con éstos.

3. La clientela

Son personas libres, no patricias, cuyas familias se encuentran bajo la protección de los "jefes de familias". Esta protección consiste en un verdadero vínculo jurídico, que recibe precisamente el nombre de clientela. El "jefe de familias" (patrono) le brinda al hombre libre (cliente), protección, asesoramiento y defensa en los litigios en que fuera parte respecto de sus intereses y negocios (patrocinio). Los clientes le deben obediencia y asistencia, colaboran con los gastos del matrimonio de las hijas del patrono, contribuyen con el pago del rescate si cae en cautiverio algún miembro de la familia de éste, lo deben apoyar con su voto en los comicios, etc. Además, patrono y cliente tienen en común que no pueden acusarse mutuamente, ni testificar el uno en contra del otro. El vínculo "patrono-cliente" tiene carácter sagrado, lo cual implica que el incumplimiento de los deberes entre sí recibe la sanción de "impuro" (sacer) que acarrea la pena de muerte⁽⁷⁾.

IV. LA CONFRONTACIÓN PATRICIA-PLEBEYA⁽⁸⁾

En un principio, el patriciado goza de todos los derechos públicos y privados en modo exclusivo, hasta tanto Roma comienza a expandirse, aumentando su poder y población. Es entonces cuando los plebeyos inician la confrontación con los patricios en procura de la equiparación. Esta verdadera lucha de clases se lleva a cabo aproximadamente desde mediados del período monárquico, extendiéndose durante toda la república, hasta que finalmente los plebeyos logran la igualdad. En rigor de verdad, esta equiparación presenta carácter formal, por cuanto una vez lograda la integridad comienza otra disputa social que divide nuevamente a la sociedad romana bajo la denominación de "óptimos" (optimates) y "populares". En otras palabras, la división en clases de la sociedad romana se mantiene más allá de la propagada igualdad. La lucha entre patricios y plebeyos, iniciada otrora en el período monárquico, y que finaliza con la equiparación entre ambos en la República, es de algún modo aparente. La nueva configuración social hace renacer la confrontación de clases.

V. LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA⁽⁹⁾

El pueblo romano, aunque pagano, es profundamente religioso. El hombre antiguo tiene inmanente su condición humana, y por lo tanto de inferioridad respecto de los dioses. Por tal motivo, la religión a través de la casta sacerdotal tiene gran importancia e injerencia en la vida romana, influyendo en el derecho público y privado. La principal figura en la organización religiosa es el rey, que es el Jefe Supremo del culto y quien preside todos los actos públicos. Mas la actividad religiosa del rey no es solitaria, sino que se encuentra asistido por los sacerdotes, quienes supervisan ceremonias, sacrificios e interpretan la voluntad de los dioses mediante "auspicios" y "presagios". Esta verdadera casta sacerdotal, patricia por excelencia, se encuentra agrupada en "colegios". Los más notorios e importantes son los denominados pontífices, augures y feciales.

1. Colegio de pontífices

Es uno de los más antiguos y se dice que su creador es el rey Numa Pompilio. Su principal rol es vigilar la correcta aplicación de todo el "derecho sagrado". Por tal motivo, no son sólo sacerdotes de determinados dioses, sino de todo el culto en general, oficiando de intermediarios entre aquéllos y los hombres. En un principio se encuentra compuesto por cuatro miembros, aumentando lentamente su número hasta arribar a quince en tiempos de Sila, durante la República. Se encuentra presidido

por uno de sus miembros, que se denomina Pontífice Máximo, que tiene exclusivamente a su cargo la misión de registrar en una "tabla blanca" (album) los principales hechos históricos que acontecen en la ciudad. El colegio de los pontífices es el encargado de conservar, atesorar, aplicar e interpretar las normas religiosas (fas) que durante el período monárquico son de algún modo, aunque discutidas, fuentes de derecho (ius), dado que no se encuentra aún diferenciado este último de lo meramente religioso. Y como únicos conocedores e intérpretes del derecho sacro (fas) asesoran a los particulares respecto de las obligaciones y derechos en los negocios que llevan a cabo⁽¹⁰⁾. También se encuentran bajo su guarda y protección los tratados firmados con otras "ciudades-estados", los calendarios, las oraciones, etc. Habrá que tener en cuenta al respecto que, no siendo popular la escritura, los pontífices son los únicos que incipientemente la conocen y aplican en las registraciones, lo que sin lugar a dudas los coloca en una posición más elevada que el resto de la población.

2. Colegio de augures

Tiene como misión primordial consultar la voluntad de los dioses respecto de los asuntos públicos con el propósito de darla a conocer. Esta función se lleva a cabo mediante los "auspicios" (auspicia). Su origen se remonta, según la leyenda, emparentado con la misma fundación de Roma, puesto que Rómulo y Remo lo integran⁽¹¹⁾.

3. Colegio de los feciales

Es también uno de los más antiguos de Roma e interviene en todo lo relacionado con los asuntos de carácter internacional, como la celebración de tratados, alianzas, declaración de guerra, etc.

VI. LAS REFORMAS DE SERVIO TULIO. EL INICIO DE LA "CRISIS MONÁRQUICA"⁽¹²⁾

Según cuenta la tradición, es el monarca etrusco Servio Tulio quien lleva a cabo una trascendental reforma política-social que, al parecer, tiene una gran influencia posterior. La reforma presenta un matiz tributario, militar y comicial.

A mi criterio, para llevarlas a cabo, los autores de la reforma han tenido en cuenta dos elementos primordiales, como son la instrumentación del censo y el conocimiento y utilización de la noción de domicilio, por lo que es menester detenerme, por su importancia, en la consideración de ambos.

En primer lugar, dividir la población según su poder adquisitivo indica que Servio Tulio y sus colaboradores implementan el censo (census). Si bien los romanos son muy afectos en la República a la realización del censo quinquenal a cargo del censor, es digno destacar que ya en la Monarquía se utiliza lo que hoy constituye una vital herramienta de gobierno. Censar la población, por supuesto con las limitaciones de su tiempo, significa la necesidad de determinar y conocer su composición, para así poder planificar medidas de gobierno futuras.

En segundo lugar, tener en cuenta el domicilio de la población para registrarla implica gobernar con mentalidad progresista y moderna. Recordemos que en la actualidad se considera al domicilio como "atributo de la personalidad" y se lo define como "el asiento jurídico de una persona". Efectuadas estas reflexiones, especialmente para remarcar la profundidad, calidad y alcance del pensamiento jurídico romano, me circunscribiré al análisis y consideración de las reformas en particular.

Señala la tradición que Servio Tulio divide la población en cuatro tribus urbanas teniendo en cuenta su domicilio. La noción de "tribu" deja de ser "étnica" para constituirse en el "lugar de domicilio". Más apropiadamente significa "circunscripción geográfica" o "barrio". Tras la reforma, las tribus se dividen en dos clases, "urbanas" y "rústicas".

Las "urbanas" son aquellas ubicadas en la misma ciudad de Roma, y son cuatro, a saber: Esquilina, Suburana, Palatina y Collina. Estas tribus permanecen siempre en igual cantidad, sin aumentar de número, pese al incremento poblacional. Están compuestas por patricios y plebeyos.

Las "rústicas o rurales" son originariamente diecisiete, luego se elevan a treinta y uno en el año 231 a.C. aproximadamente, teniendo cada una de ellas una denominación particular, v.gr., Aemilia, Galeria, Camilia, etc.

La población es dividida en cinco clases, según su riqueza fundiaria (propiedad en tierras). Para determinar esto último se tiene en cuenta la cantidad de "yugadas" de tierra que posee cada persona. La "yugada" es una medida antigua romana que abarca la extensión que recorre un buey de labranza durante una jornada de labor desde el alba hasta el anochecer.

De acuerdo con este criterio, la división es la siguiente: Primera clase: 20 yugadas de tierra o su equivalente a 100.000 ases. Segunda clase: 15 yugadas de tierra o su equivalente a 75.000 ases. Tercera clase: 10 yugadas de tierra o su equivalente a 50.000 ases. Cuarta clase: 5 yugadas de tierra o equivalente a 25.000 ases. Quinta clase: 2 yugadas de tierra o equivalente a 11.000 ases.

Los integrantes de estas cinco clases se encuentran obligados a pagar tributo en proporción a su riqueza y se denominan "asiduos" (asidui). Es decir que son contribuyentes permanentes, que deben prestar, además, el servicio militar, proveyéndose de equipamiento, armamento y avituallamiento.

Todos aquellos que no alcanzan a integrar la quinta clase, o sea, que no poseen propiedades fundiarias, no pagan tributo y se subdividen del siguiente modo:

En primer término, los que tienen una fortuna de 1.500 a 11.000 ases. Se los conoce como proletarios (proletari), por cuanto contribuyen sólo con su prole a la comunidad y tienen la obligación de prestar el servicio militar como soldados de reserva, sin armas, pero con la posibilidad de equiparse con las pertenencias de los caídos en combate.

En segundo lugar, los que poseen menos de 1.500 ases y que por dicha razón sólo están nombrados o registrados en el censo (capite censi), pero no tienen ninguna obligación tributaria o militar.

Pues bien, a su vez cada una de las cinco primeras clases es dividida en un número desigual de "centurias" a los efectos del "voto público". De este modo le corresponden a la primera clase 80 centurias; a la segunda, tercera y cuarta clases 20 centurias a cada una, y a la quinta 30 centurias.

Cada "centuria" se encuentra por su parte fraccionada en una mitad de jóvenes (iuniores) en edad de servicio militar de 18 a 46 años, y en otra mitad de personas mayores (seniores) de 46 a 60 años, que se encuentran en situación de reserva.

La reforma añade por encima de las centurias de la primera clase, 18 centurias de caballería denominadas "caballeros" (equites), constituida por los jóvenes de las más ricas familias romanas. A este respecto he de señalar que se trata de las familias de mayor poder adquisitivo, por cuanto en la provisión del equipo militar, sustento, personal de servicio, etc., enteramente a su cargo, se debe agregar los caballos, el pienso y el personal de mantenimiento de éstos.

Por fin, Servio Tulio dispone la creación, entre la primera y segunda clase, de dos centurias de ingenieros, y dentro de la quinta clase, dos centurias de músicos y una de soldados desarmados como reserva.

En síntesis, las centurias suman ciento noventa y tres⁽¹³⁾, pero la reforma presenta la singularidad de que al momento de votar deben hacerlo en primer término la clase de caballeros, y luego la primera clase, obteniendo, de votar ambas en el mismo sentido, mayoría, es decir, noventa y ocho votos, lo que torna inocua la voluntad del resto de la población representada en las restantes clases.

Analizando detenidamente el interés político-económico de los ciudadanos integrantes de la primera clase y la de caballeros, encontramos una mayor afinidad entre éstos en comparación con el resto. Esto implica que es más afín que voten en el mismo sentido, lo que trae aparejada una

preponderancia en el sistema de las clases más adineradas e influyentes, conformadas por los patricios, sobre el resto de la población.

En mi criterio, de ser cierta la atribución de estas reformas a Servio Tulio, la situación del ciudadano medio empeora, por cuanto se encuentra en una posición más difícil, ya que está "censado", o sea "registrado", y debe tributar con arreglo a la declaración de riqueza, aportando en consecuencia al equipamiento del ejército y prestando servicio activo en él; pero no tiene igual correlato al momento de votar, en virtud de que es la clase pudiente la que decide por todos.

En otras palabras, la situación de la población media, generalmente plebeya, empeora, ya que adquiere mayores compromisos y obligaciones, pero al momento de decidir, se encuentra sometida a la voluntad de una minoría más rica, constituida por los patricios.

Diversos autores ponen en duda que Servio Tulio sea el autor de estas reformas, y suponen que son posteriores a él. En este sentido, afirman que es la tradición la que atribuye su creación al monarca etrusco. Pienso que posiblemente la verdad se encuentre en una posición intermedia, dado que es muy probable que Servio Tulio, y su gobierno, hayan delineado e iniciado la implementación, pero sin agotarlas, siendo después, en el período republicano, cuando se profundizan y entran en pleno vigor.

Lo cierto es que tras estas reformas, independientemente de la determinación exacta en cuanto a su origen, comienza la declinación política institucional de los viejos comicios curiados, y la aparición pujante de los comicios centuriados, luego transformados en tribados, y en modo casi paralelo, en comicios plebeyos (concilia plebis).

Una última reflexión merece el tema. Las citadas reformas producen una fuerte insatisfacción social, agravada luego por el despotismo del último rey etrusco, Tarquino "el Soberbio", que influye notoriamente, acelerando "el fin del sistema monárquico" y "el paso a la república", resultando evidente, según mi opinión, que el "momento crítico histórico" que produce el cambio de sistema se origina con las aludidas reformas de Servio Tulio.

FRANJA MORADA

VII. LA PRINCIPAL FUENTE DE DERECHO BAJO LA MONARQUÍA(14)

La principal fuente de derecho en el período monárquico es la "costumbre jurídica" (*mores maiorum*), transmitida de generación en generación por la casta sacerdotal y monopolizada en cuanto a interpretación y aplicación en favor de la conveniencia de la clase patricia.

Entiendo por "costumbre jurídica" la observancia de la comunidad de ciertas pautas de conducta consideradas de acatamiento obligatorio, por cuanto, de incurrir en lo contrario, serán pasibles de sanción.

Se habla también que son fuentes de derecho en este período las denominadas "leyes regias" (*leges regiae*), pero soy del criterio de que éstas no han existido efectivamente. Se trata, para quienes las consideran "fuente de derecho", de leyes aprobadas por los comicios a propuesta de los reyes Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Servio Tulio, pero sin precisarse, en realidad, el contenido o, al menos, que éste fuese jurídico. Sólo hallamos una mera referencia en ciertos pasajes del Digesto atribuido a Pomponio, Paulo y Marcelo, que sólo hablan de ellas como una recopilación del pontífice máximo Papirio.

El fundamento del criterio al cual me adhiero sostiene que esta recopilación, de ser cierta, data de fines de la República, y no del período monárquico. Por demás, su contenido manifiestamente religioso, indica que nunca ha podida ser sancionada por los comicios curiados del período monárquico en virtud de que éstos jamás han tenido injerencia en disposiciones de carácter religioso. Por lo expuesto, como he indicado, la principal fuente de derecho en la Monarquía es la costumbre (*mores maiorum*).

VIII. EL IUS Y EL FAS

Se entiende por *ius* lo referente al derecho y el *fas* a lo religioso. En los tiempos primitivos, en Roma, no existió diferencia entre norma jurídica (*ius*) y norma religiosa (*fas*). Por el contrario, se encontraban unidos, de modo tal que "el *fas* estuvo identificado con *elius*, pues ambos, para que determinado acto o comportamiento fuera lícito, exigían que éste estuviera conforme a la voluntad de los dioses. Con el tiempo, por un proceso de abstracción, *ius* y *fas* entrañan la norma misma que prescribe la licitud o ilicitud de los actos humanos. La estrecha vinculación del *fas* con el *ius* en Roma subsistió durante largo tiempo⁽¹⁵⁾". En otras palabras, la jurisdicción religiosa abarcaba lo jurídico, correspondiendo a la casta sacerdotal, patricia por excelencia, distinguir lo lícito de lo ilícito. Mas luego, "los primeros prudentes romanos, que pertenecieron a la clase pontifical, comenzaron a formular la distinción entre las normas del *ius divinum*, que se referían a las relaciones del hombre con los dioses, y las del *ius humanum*, que regulaban la de los hombres entre sí"⁽¹⁶⁾. Por fin, "cuando se llega a la definitiva secularización del *ius*, éste queda configurado como una pura creación humana y, desde entonces, el *fas* equivale únicamente al derecho divino, es decir, a lo lícito religioso, a la norma que es divina, no sólo por su fuente, sino también por el objeto que tutela⁽¹⁷⁾".

La evolución expuesta conlleva a la siguiente reflexión, que demuestra la humanidad y progreso del derecho romano. Este último parte de la fusión de norma religiosa y jurídica con una gran injerencia de la clase pontifical para dirimir los conflictos cotidianos. Los sacerdotes interpretan y aplican la ley, de algún modo son la ley misma. Luego, el avance de las ideas produce la bifurcación y absoluta separación de lo divino y lo jurídico, obteniéndose una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos. Prueba de ello es la situación de la mujer en Roma, puesto que parte de una sumisión completa al jefe de familias, al que pertenece en el sistema antiguo, para llegar a ser "jefa de familia", es decir, *sui iuris*, durante el período clásico. Finalmente, una vez que cae definitivamente el Imperio Romano de Oriente con la toma de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año 1453, el Corán reemplaza la normativa jurídica vigente, originándose nuevamente la fusión de lo religioso y el derecho, y la mujer nuevamente es sometida al poder de los hombres que dirigen la familia.

IX. LA CRISIS DEL PERÍODO MONÁRQUICO⁽¹⁸⁾

Puedo aseverar que el paso del período monárquico a la República no ha sido repentino, sino paulatino, y lleva aproximadamente más de una centuria. En rigor de verdad, como lo señalé *ut supra*, ningún cambio estructural en la historia de Roma se origina en modo abrupto. Por el contrario, es el producto gradual de acontecimientos de diversa índole que finalizan en la transformación del sistema, matizados con picos de violencia, persecuciones, asesinatos, etc., lo que se conoce como "período de crisis".

En verdad, las causas que motivan el cambio institucional han de encontrarse en el período comprendido entre el gobierno del rey etrusco Servio Tulio y la sanción de la ley de las XII Tablas⁽¹⁹⁾. Durante este lapso encontramos las causas y motivos del cambio institucional romano.

La impopularidad de los Tarquinos comienza con las míticas reformas del monarca prealudido, que en verdad, si bien terminan de implantarse mucho después, en su inicio generan en el pueblo romano el conculcamiento de sus derechos, traducido en el incremento de las cargas tributaria y militar, y en la falta de correspondencia política debido a la disminución de la capacidad de votar. Este "abuso político" de la dinastía etrusca, que la torna impopular, se agrava durante el reinado del último Tarquino, apodado sabiamente por el pueblo "el Soberbio", que gobierna de modo despótico conculcando, aún más, los derechos de los ciudadanos romanos.

La tradición cuenta, como dijera, que durante el gobierno del último de los etruscos se produce una revuelta popular a causa del abuso sexual perpetrado por su hijo Sexto en contra de Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino, también miembro de la familia real. El mismo relato señala que el pueblo le impide al rey Tarquino, ausente en ese momento de Roma, regresar, por lo cual se instala en Etruria ⁽²⁰⁾, donde conspira con la ayuda de los acólitos que continúan residiendo en Roma a los efectos de reinstalar su gobierno, lo cual no logra, pese la lucha armada que se produce entre ambos bandos.

Depuesta entonces la dinastía etrusca, la ciudad continúa, en principio, con la organización institucional que conoce, es decir, básicamente el Senado y los comicios, aunque sin la figura del rey. Esto último a pesar de la constante conspiración de los partidarios del sistema monárquico que buscan su restauración, aunque sin la presencia de los Tarquinos.

Este período histórico es en verdad confuso por la falta de elementos indubitados que permitan esclarecerlo, siendo la leyenda, con los reparos que conlleva, el elemento más valioso para su estudio. Lo cierto es que después de la caída del último rey etrusco, las instituciones políticas que al parecer continúan vigentes son el Senado y los comicios. La institución representativa de la ciudad que encarna el rey es la que padece los más variados vaivenes, hasta que se formalizan en su reemplazo las magistraturas, delineándose finalmente el sistema republicano definitivo de gobierno. Por esto, entonces, Roma es gobernada tras la caída de la monarquía, según distintas versiones, por diversos magistrados, que en un principio tienen rasgos más monárquicos que republicanos, incluso con algún sesgo vitalicio y personal. Estos magistrados reciben distintas denominaciones, aunque bien puede ser que existan, pero durante distinto tiempo, dentro del mismo período de transición. Así se habla, indistintamente, de cónsul, dictador, decenvirato, pretor (praetores), jefe del pueblo (magister populi), jefe de la caballería (magister equitum), etc. (21).

Por tales motivos me permito señalar que la sanción de la ley de las XII Tablas es el fin de la crisis institucional, y además es el punto de partida del nuevo sistema republicano, por cuanto implica "fijar por escrito" el derecho que es oral (costumbre). A mi parecer, esto es crucial, por cuanto significa una propuesta de gobierno diferente. El derecho, hasta ese momento, es no escrito, sólo conocido por la casta sacerdotal, es decir, patricia, que lo manipula según propia conveniencia, y que conlleva un mayor conculcamiento de quienes no pertenecen a la clase gobernante, o no gozan de su protección, es decir, la clase plebeya (22).

La sanción de la ley de las XII Tablas, aunque con defectos, en cuanto no garantiza la igualdad jurídica plena entre patricios y plebeyos, significa el comienzo de un nuevo sistema en el cual estos últimos comienzan a erigirse como clase definida y combativa, en pos de la equiparación a los primeros. Fijar por escrito el derecho vigente a través de la ley de las XII Tablas, entiendo, es el punto de partida de la organización institucional política y de la grandeza de Roma, que como corolario la torna en imperio.

A este respecto sostiene D'Ors que "la ley decenviral fue superada por el derecho posterior, pero nunca fue expresamente derogada. El tradicionalismo jurídico de los romanos prefería superponer lo nuevo a lo antiguo, y no desautorizar a los antepasados, a quienes se atribuía la autoridad de fundadores del derecho (auctoritas irua condenatium). De este modo, el progreso jurídico, muy práctico y original, se produjo sin convulsiones revolucionarias" (23).

Una "ciudad-estado" que se preocupa en convertir sustancialmente la expresión de su derecho en oral a escrito denota la madurez necesaria para establecer claras pautas de conducta conocidas por todos. Es, por otra parte, el comienzo escrito del derecho del mundo occidental. La ley de las XII Tablas significa el punto de partida del derecho que hoy nos toca en vida conocer y defender. También es menester dejar en claro que la sanción de esta ley no implica ipso facto la instauración del nuevo sistema republicano de gobierno perfectamente definido como se conoce y estudia, sino que debe transcurrir todavía un tiempo hasta que los romanos logren obtener el perfil político republicano. Pero indudablemente la mencionada norma legal inicia y acelera el proceso, por cuanto ella busca instaurar "seguridad" y "confianza" en la población. En otras palabras, intenta "democratizar legislando", que en definitiva es el logro político del sistema republicano.

Por estas razones, fundamentalmente me he inclinado a considerar, dada su gravitante importancia, como "hito histórico relevante", la sanción de la "ley de las XII Tablas como punto de comienzo del período republicano (año 451 a.C.), por sobre la tesis que lo considera a partir de la creación definitiva del Consulado en el año 367 a.C.

X. LA CREACIÓN DE LA LEY DE LAS XII TABLAS(24)

La principal fuente histórica que se refiere a la sanción de la ley de las XII Tablas es la tradición. Ésta cuenta que aproximadamente entre los años 462 y 460 a.C., el tribuno C. Terentilio Arsa propone, para poner límites a los abusos de la clase gobernante (patricios contra los plebeyos), la nominación de una magistratura extraordinaria de cinco miembros, con el fin de que redacten leyes de "imperio consular", reglando los intereses de la plebe en defensa del avasallamiento patricio. Esta proposición tiene una férrea oposición de la clase patricia, que vislumbra la pérdida de su hegemonía política y económica. A pesar de ello, C. Terentilio Arsa consigue la aprobación del envío de una comisión de tres miembros, compuesta por Postumio Albo, A. Manlio y Sulpicio Camerino, para estudiar el sistema legislativo de Grecia, la "Magna Grecia" (Sicilia) y especialmente las leyes atribuidas a Solón.

En el año 455 a.C., ante la cada vez más fuerte presión plebeya, se nombra finalmente, a propuesta del cónsul Appio Claudio, una magistratura extraordinaria de diez miembros para que dicten un cuerpo de leyes escritas que rijan al pueblo romano, tomando el nombre de "Decenvirato"

(decenviri legibus scribundis)⁽²⁵⁾, cuyos integrantes, exclusivamente patricios, asumen "poderes consulares con la facultad de dictar leyes".

Una vez retornada la comisión primitiva que viajara a Grecia, el Decenvirato en pleno, en el año 451 a.C., redacta "Diez Tablas de leyes", que son sancionadas por los "comicios centuriados", y luego expuestas públicamente. Posteriormente, al advertir que la nueva ley se encuentra incompleta, una nueva composición del Decenvirato, integrado esta vez, además, por tres miembros plebeyos, decide completarla mediante el agregado de "dos tablas", quedando configurada la redacción definitiva de las "Doce Tablas", como se conoce actualmente⁽²⁶⁾.

FRANJA
MORADA

Capítulo IV - Período Republicano

CAPÍTULO IV - PERÍODO REPUBLICANO(1)

Se conoce tradicionalmente como republicano el período comprendido entre los años 451 y el 27 a.C. En él, se advierten las siguientes características, a saber: a) intensificación motora de la lucha de clases propiciada entre patricios y plebeyos; b) obtención de conquistas sociales por parte de estos últimos; c) búsqueda y logro de la equiparación patricio-plebeya; d) estabilidad política interna de Roma; e) consolidación expansiva externa, puesto que deja de ser la defensiva aldea del Lacio para convertirse en potencia exclusiva del Mediterráneo luego de derrotar definitivamente a Cartago; f) aparición fulgurante de un nuevo modo de crear derecho a través de los magistrados republicanos, esencialmente el pretor, que configura el "derecho honorario" como adecuador y corrector del rígido "derecho decenviral".

El sistema de gobierno republicano nace y se afianza sobre la base estructural monárquica, dado que mantiene el Senado y los comicios, aunque con variaciones, y reemplaza el poder personal, vitalicio e irresponsable del rey por un sistema de gobierno colegiado, periódico y de responsabilidad efectiva.

I. LAS MAGISTRATURAS. CONCEPTO. CARACTERES Y CLASIFICACIÓN(2)

Las magistraturas son cargos públicos, colegiados, electivos, periódicos, responsables y gratuitos, ejercidos en nombre y representación del pueblo romano.

Del concepto expuesto se desprenden las características propias de las magistraturas republicanas: a) Pluripersonales o colegiadas, por cuanto son ejercidas por dos o más personas. b) Electivas, dado que sus integrantes son elegidos en los comicios mediante voto popular. c) Periódicas, porque desempeñan el cargo por un período determinado. d) Responsables, pues deben dar cuenta de sus actos de gobierno ante el comicio que los elige. e) Gratuitas, porque consiste un verdadero honor ejercerlas y, por ende, no perciben suma alguna al respecto.

Las magistraturas se pueden clasificar doctrinariamente en:

1. **Ordinarias y extraordinarias.** Las primeras son las que provienen de la carrera de las magistraturas, constituyen la estructura misma del Estado en tiempos normales y son elegidas periódicamente por los comicios, v.gr., consulado, pretura, edilidad, cuestura, tribunado, censura. Las segundas, en cambio, son las que emergen en tiempos particularmente difíciles y excepcionales, durando en el cargo sólo el tiempo que demande la solución del conflicto que origina su nominación, por ejemplo, dictadura, decenvirato, etc.

A modo de aclaración debo destacar que ambos tipos de magistraturas forman parte del orden constitucional romano, por cuanto su funcionamiento es contemplado y regulado por dicho orden. Es decir que el mismo sistema constitucional contempla el ejercicio del poder por parte de las magistraturas extraordinarias cuando las ordinarias colapsan en gobernar.

2. **Mayores y menores.** Esta clasificación está relacionada con la facultad de consultar la voluntad de los dioses (auspiciar). Únicamente las magistraturas mayores tienen esta importante facultad (consulado, pretura, censura, dictadura), íntimamente vinculada con la convocación del Senado y los comicios. Para llevar a cabo este trascendental acto se debe consultar siempre previamente a los dioses para que revelen si el día es propicio (fasto) o no (nefasto) para concretar la convocación. Por su parte, los magistrados menores (edilidad, curul, cuestura) carecen de esta facultad.

3. **Curules y no curules.** Los magistrados curules son aquellos que tienen el alto honor de sentarse en "la silla curul", una banqueta plegadiza con adornos de marfil, frente al pueblo. Se debe dejar en claro al respecto que los juristas romanos no tienen dudas de que "el único soberano es el pueblo" y que éste solo se encuentra representado en los comicios. Por ende, el magistrado debe permanecer respetuosamente en pie ante el comicio, y sólo a modo de excepción se le permite sentarse con su autorización. Por lo general, los magistrados mayores son también curules, a saber, cónsul, pretor, etc. En cambio, los no curules son aquellos que no poseen dicha facultad, v.gr., cuestor.

4. **Patricias y plebeyas.** Las magistraturas patricias son, en origen, las reservadas para quienes integran esta clase, aunque, después, producto de las conquistas sociales, los plebeyos logran el acceso a ellas, v.gr., cónsul, pretor, cuestor, etc. Por su parte, las magistraturas plebeyas son las que únicamente desempeñan los plebeyos, quedando vedadas para siempre a los patricios.

II. IMPERIUM Y POTESTAS⁽³⁾

Son las facultades que los magistrados republicanos emplean para ejercer sus funciones. El imperium es el atributo de mando que le permite ordenar al pueblo y ser obedecido por éste. Por el mismo, gobierna el Estado, dirige el ejército, convoca y preside el Senado y los comicios, y consulta los auspicios. La potestas, que implica varias facetas, es la facultad de dirigirse al pueblo con fuerza de ley. Por ella, el magistrado se dirige al pueblo dictando ordenanzas (ius edicendi) y administra justicia en lo civil y criminal (iurisdictio).

III. LA CARRERA DE LAS MAGISTRATURAS (CURSUS HONORUM) ⁽⁴⁾

>Se denomina "carrera de las magistraturas o de los honores" (cursus honorum) el camino político que debe recorrer inexorablemente todo ciudadano interesado en ejercer el gobierno de Roma. La carrera implica cumplir con determinados requisitos y exigencias destinadas a que el ciudadano adquiera la experiencia necesaria de gobierno en el rol de mando, permitiéndole arribar a las magistraturas máximas (consulado y pretura).

El ordenamiento de "la carrera de los honores" implicó el paso de varios siglos hasta lograr su configuración definitiva. Puedo afirmar, en modo básico, que su fundamento constitucional radica en el plebiscito atribuido al tribuno L. Genuncius (339 a.C.); la lex Villia de Annalis, dictada a propuesta del tribuno Lucius Villius (180 a.C.); la lex Cornelia de Magistratibus, dictada por Cornelio Sylia (81 a.C.), y la costumbre.

Producto de este marco constitucional, la carrera política del ciudadano romano se manifiesta en dos aspectos, el militar y el político, pudiéndose advertir que en cierto momento prevalece uno sobre otro y, después, ambos confluyen, complementándose.

Desmenuzando lo expuesto, destaco que la carrera política es eminentemente militar en su primer tramo, iniciándola el ciudadano a los 17 años mediante el ingreso al servicio activo en el ejército por espacio mínimo de diez años⁽⁵⁾. Ésta es una carga pública, y su incumplimiento trae consigo la aplicación de la "tacha de indignidad" para el trasgresor, apartándolo ab initio del ejercicio de sus derechos políticos.

Cumplido el servicio militar, es decir, a la edad de 28 años, siempre que el ciudadano obtenga como mínimo el cargo de comandante de legión (tribunus militum), se encuentra en condiciones de iniciar la carrera de la magistratura propiamente dicha. A mi entender, debo aclarar que ambos requisitos son de cumplimiento inexorable, aunque no al unísono. La edad siempre es un tope, puesto que debe cumplir diez años de leva forzosa entre los 17 y los 28 años, y la graduación militar es de consideración mínima, dado que puede alcanzar incluso una mayor jerarquía. Nada obsta a que el ciudadano romano logre completar ambos requisitos después de los 28 años, pero debe completarlos. Claro está que las exigencias aludidas luego permiten excepciones de carácter político, sujetas a consideración y conveniencia del Senado en las postrimerías del sistema republicano, lo que produce fisuras en el andamiaje político expuesto.

El orden de los distintos cargos, de menor a mayor, es el siguiente: cuestor, edil, pretor, cónsul. La censura se encuentra fuera de la carrera de los honores, pero por costumbre generalmente se nombra censor a un ciudadano que hubiese cumplido con el consulado, aunque median excepciones. El indicado es el orden que deben respetar los patricios. Por su parte, los plebeyos ejercen el tribunado, intercalado entre la edilidad y la pretura. Otro de los requisitos exigidos es la edad mínima de 40 años para alcanzar la pretura y 43 para el consulado.

1. Consulado

Es el cargo máximo al que puede aspirar y ejercer un ciudadano romano. Es quien tiene el mayor poder "en ejercicio del imperium" y "la potestas". En otras palabras, los cónsules representan y dirigen el Estado, son jefes supremos del ejército, convocan y presiden el Senado y los comicios, sometiéndoles las cuestiones que deben tratar y decidir, celebran tratados de paz con países extranjeros, se dirigen al pueblo con fuerza de ley e imparten justicia. Además, ejercen el poder de mando sobre los restantes magistrados republicanos que se encuentran por debajo, según lo ordena "la carrera de las magistraturas", originando lo que se conoce en el mundo moderno como *per saltum*⁽⁷⁾.

2. Pretura

Es la magistratura más importante desde el punto de vista jurídico, como a nivel político lo es el cónsul. En la división tácita de funciones, según emerge del propio orden constitucional romano, los cónsules pueden llevar a cabo cualquier acto de gobierno reservado a los otros magistrados inferiores en grado, pero por razones de índole práctica gobiernan y dirigen el ejército y las guerras. Adviértese que a lo largo de la historia de Roma siempre han sido sólo dos los cónsules y, por ende, no les resta tiempo para la actividad judicial. Esta última le está reservada a los pretores, que si bien comienzan siendo dos, otros opinan que fue uno solo; al aumentar la población de Roma, necesariamente hubo de elevarse su número en proporción a ese crecimiento.

Puedo señalar, sin ánimo de equivocarme, que el pretor es el verdadero iniciador y forjador del derecho privado del mundo occidental. De su actividad cotidiana en el Foro surgen los principios jurídicos más importantes y novedosos que conforman las principales instituciones del derecho privado, modificando, humanizando, actualizando y adecuando los duros preceptos de la "ley de las XII Tablas", dando origen al más importante de los derechos de Roma, el denominado "pretoriano" u "honorario". Así como el cónsul enarbola en la máxima potencia "el imperium", el pretor hace lo propio con "la potestas", originando verdadero derecho a través de la acción (*actio*) creada para los litigantes. Esto es así, por cuanto el pretor tiene importancia estratégica en la creación y modificación del derecho vigente en Roma, cumpliendo dicha actividad en la primera etapa del "procedimiento civil romano", conocido también como "procedimiento del juez privado", abarcando la República y el Alto Imperio, aunque su mayor esplendor lo obtiene en la primera de las etapas históricas nombradas.

Logros importantes del pretor, sólo a modo ejemplificativo, son los siguientes: consideración del vínculo de sangre (*cognaticio*) por sobre el civil (*agnaticio*); permitir a la mujer ser "cabeza de su propia familia" (*sui iuris*); la introducción de una nueva forma de acceder a la herencia (*bonorum possessio*); la responsabilidad patrimonial del padre de familia (*pater familias*) en actividades del hijo (*filius familias*); creación de las denominadas "acciones de peculio" (*actionis adiecticia qualitates*); introducción de la compraventa; valorar el consentimiento por sobre las formas en el acto jurídico, etc.

La labor del pretor crea un verdadero derecho distinto al "quiritario" proveniente de la "ley de las XII Tablas", modificándolo suficientemente hasta enriquecerlo y tornarlo incluso más humano y equitativo. En esto radica el éxito y "pervivencia" del derecho romano y su "transfiguración" en "derecho moderno occidental", incluido el nuestro. Los romanos no restan sujetos en el tiempo,

según los mandatos de la "ley de las XII Tablas", sino que saben crear los mecanismos necesarios⁽⁸⁾ (v.gr., la pretura) para lograr que su primitivo derecho se adecue a la nueva realidad jurídica deparada por los pueblos conquistados y luego incorporados al imperio. Este "derecho nuevo", vigorosamente enriquecido, humanizado y actualizado, se conoce como "derecho pretoriano u honorario".

En Roma existen dos clases de pretores, el urbano y el peregrino. La "pretura urbana" es la más antigua y nace aproximadamente en el año 367 a.C. Luego, producto de las guerras y la interrelación con los pueblos conquistados, se origina la "pretura peregrina" en el año 242 a.C. El pretor urbano, entonces, queda circunscripto sólo a los conflictos entre patricios, mientras que el peregrino interviene en las controversias suscitadas entre patricios y extranjeros o entre extranjeros entre sí. Es evidente que mientras el pretor urbano sólo aplica el ius civile derivado de la "ley de las XII Tablas", el pretor peregrino, por estar en contacto con los distintos pueblos y culturas, aplica el derecho de gentes (ius gentium). Por tal motivo, la pretura peregrina alcanza mayor importancia que la urbana, originando las mejores soluciones y creaciones jurídicas por estar en contacto con otros pueblos, mejorando y adecuando el viejo tronco romano a las necesidades jurídicas de su tiempo a través de la equidad (aequitas).

Más tarde, el edicto del pretor es compilado en tiempos del príncipe Adriano (dinastía antonina), a su pedido expreso, por el mayor jurista conocido de la época, Salvio Juliano, perdiendo entonces el pretor su importancia y gravitación, por cuanto le quita la facultad de crear derecho, sujetándolo a la aplicación de dicho edicto, el cual justamente se denomina "Perpetuo"⁽⁹⁾.

3. Edilidad

Surge como magistratura curul en el año 367 a.C., y tiene las facultades de organizar los grandes juegos; supervisar los graneros y almacenes; inspeccionar la buena conservación de los edificios, caminos y mercados; controlar todo lo atinente al abastecimiento de la ciudad y el valor de los precios; manejar el orden y la seguridad pública; fiscalizar el servicio de incendio y la vigilancia nocturna; ordenar el funcionamiento de las asociaciones, etc.⁽¹⁰⁾.

4. Cuestura

Si bien es considerada una magistratura de rango menor, es una de las más antiguas de Roma, puesto que nace juntamente con los cónsules en carácter de auxiliar. El cuestor carece de imperio y de poder coercitivo, presentando sus funciones dos aspectos: por un lado, administra el tesoro público; y, por otro, ejerce funciones jurisdiccionales en la sustanciación de los procesos capitales, especialmente el delito de parricidio (parricidium)⁽¹¹⁾, que consiste en el atentado contra la vida de un "padre de familia" por parte de cualquier individuo de la comunidad, constituyéndose en el antecedente directo del actual delito de homicidio agravado por el vínculo.

5. Censura

Surge como magistratura independiente en el año 443 a.C. Tiene como característica relevante la "no permanencia", debido a que los censores, elegidos por los comicios centuriados a propuesta de los cónsules, sólo son nominados para llevar a cabo las operaciones del censo cada cinco años. La lex Aemilia, del año 435 a.C., regla su funcionamiento efectivo en los primeros dieciocho meses del lustro por el cual son elegidos. Sus funciones son, en un principio, determinar mediante la confección del censo la situación patrimonial personal de los ciudadanos con el fin de fijar su carga

tributaria; luego se le añade "la custodia del honor y dignidad" de éstos, puesto que, mediante la imposición de la "nota o tacha de infamia o ignominia"⁽¹²⁾, los puede inhabilitar políticamente, privándolos de los derechos de votar, ejercer la carrera de las magistraturas y de los cargos militares. El censor obtiene su máximo esplendor después de la sanción del plebiscito Ovinio, del 312 a.C., que lo autoriza a confeccionar la lista de los ciudadanos que acceden al Senado cada cuatro años (lectus senatus).

V. LAS MAGISTRATURAS ORDINARIAS DE ORIGEN PLEBEYO⁽¹³⁾

1. Tribunado de la plebe

Nace como producto de la intensa lucha social patricia-plebeya. En rigor de verdad, se la considera tradicionalmente como una magistratura, pero no lo es íntegramente, dado que carece de imperium y potestas, con lo cual es más apropiado, en todo caso, valorarla como una "cuasi magistratura". Tiene como facultad esencial "el poder de veto" (intercessio), por el cual puede paralizar, sin necesidad de fundamento alguno, cualquier decisión de los magistrados, incluso otro tribuno, y también de los restantes órganos republicanos, tan sólo en defensa de los intereses de la plebe. Es lo que se conoce técnicamente como "poder negativo" o el "poder del no". También convoca y preside los concilios de la plebe (concilia plebis) y arbitra los litigios entre plebeyos. A los efectos de cumplir mejor su cometido, el tribunado es investido de sacralidad (sacrosancti), lo cual significa que quien atenta contra su vida es considerado "impuro" (sacer) y pasible de ser muerto de inmediato y legítimamente por su escolta de seguridad o, si es el caso, por cualquier integrante de la comunidad.

MORADA

2. Edil de la plebe

Es una magistratura que se desempeña como auxiliar del Tribuno y es elegida en los "concilios de la plebe". Tiene las funciones de custodia de la documentación vinculada con los derechos de la plebe; protege a los plebeyos contra los abusos de las prestaciones de trabajos públicos, etc. Posteriormente pierde injerencia cuando los plebeyos acceden a la edilidad curul y sus funciones son absorbidas por esta última.

VI. LAS MAGISTRATURAS EXTRAORDINARIAS⁽¹⁴⁾

Son aquellas que no están contempladas en la "carrera de los honores" (cursus honorum), sino que son una excepción necesaria a ella, dispuesta por el propio orden constitucional romano. Puedo citar, entre las principales, la dictadura y el decenvirato.

1. Dictadura

La designación de dictador tiene lugar en casos excepcionales de gravedad institucional, tales como sofocar una rebelión, rechazar un ataque enemigo, dirigir una guerra de resultado incierto, etc. El momento crítico que se debe superar ha de ser particularmente riesgoso a los efectos de justificar su designación. El dictador, en principio, es elegido por los cónsules ante un pedido expreso del Senado; luego esta facultad pasa directamente al pueblo reunido en comicios centuriados. Debe permanecer como máximo en el cargo seis meses, o un tiempo menor si el magistrado que lo designa debe finalizar antes su mandato. No puede ser reelegido inmediatamente, y si concluye el cometido por el cual ha sido elegido antes de los seis meses, también cesa en sus funciones. Todos los recaudos mencionados son justamente para evitar la perpetuación en el cargo. Posee todos los atributos y facultades de los magistrados republicanos que no ejercen su mandato mientras se encuentra en funciones el dictador, permaneciendo en sus cargos, pero paralizados en sus funciones. Las decisiones del dictador son inapelables, dado que durante el período de su designación se suspende a los ciudadanos romanos el derecho de apelar ante los comicios la aplicación de la pena capital (*provocatio ad populum*).

Es evidente que la designación de dictador conlleva un retorno a la magistratura de rasgo unipersonal (rey), que precisamente se intenta denostar mediante la colegiación dirigencial del Estado (magistrados), pero la gravedad y complejidad de la circunstancia a superar justifica la acumulación de poderes en una sola persona. Precisamente por este mismo motivo, y ante la difícil misión que tiene por delante en tan poco tiempo, se torna imprescindible que su elección recaiga en una persona proba y versada en la temática sujeta a resolución, v.gr., un militar avezado. Destaco mi opinión que en la raíz de esta magistratura extraordinaria se encuentra buena parte del origen de la concentración del poder en manos del Príncipe en el Alto Imperio⁽¹⁵⁾.

FRANJA

2. Decenvirato

Es conocido también como "Decenvirato legislativo" (*decemviratus legibus scribundis*), que tiene a su cargo la creación de la "Ley de las XII Tablas". Es creado en el año 445 a.C. con la finalidad de dictar la citada ley, para lo cual se le conceden todos los poderes de los magistrados ordinarios, los cuales quedan suspendidos en el cumplimiento de sus funciones. Está compuesto por diez miembros y se le fija una duración de un año, tras lo cual debe dictar la primera ley escrita. En dicho lapso se dictan las primeras "diez tablas" y es necesario crear un nuevo "decenvirato" con una distinta composición en sus miembros, que incluye tres plebeyos, para sancionar las dos últimas tablas, originando la versión definitiva de las "XII Tablas". Por último, como pretenden perpetuarse en el poder extendiendo su mandato por demás del plazo conferido de un año, instados y dirigidos por uno de sus miembros, Apio Claudio, una rebelión popular los derroca y restablece las magistraturas ordinarias en el año 449 a.C.

VII. OTRAS MAGISTRATURAS Y FUNCIONARIOS INFERIORES

Además de los magistrados nominados en el acápite precedente, tenemos otros de menor importancia, que pueden ser de carácter ordinario o extraordinario, según el caso, y son elegidos por los "comicios tribados".

Entre los ordinarios se encuentran los que controlan la fabricación de monedas; los que custodian las prisiones; los que inspeccionan las grandes vías urbanas y rurales; los que persiguen el pago de impuestos y contribuciones; los que efectivizaban la vigilancia en ambos lados del Tíber y por la noche, etc. Entre los extraordinarios se hallan los designados para la medición y distribución de las colonias fundadas por Roma; los encargados de asignar tierras públicas; los que actúan en calidad de acusadores públicos en las causas criminales (*duoviri perduellionis et parricidii*); los encargados de controlar las donaciones de las tierras públicas a los dioses; los encargados de los préstamos de los bancos públicos; los encargados de dirigir la flota, etc.⁽¹⁶⁾.

Además, se encuentran también entre los funcionarios de rango inferior los que colaboran con la gestión de los magistrados y reciben paga del Estado, denominados genéricamente apparitores. Entre éstos podemos citar a quienes tienen a su cargo los "registros públicos" por orden de los magistrados (scribae); los que acompañan a los magistrados simbolizando su autoridad jurisdiccional y ejecutan sus órdenes (lictor); los que hacen de mensajeros y reciben a las personas que solicitan entrevistar al magistrado (viatores); los pregoneros, que anuncian la fecha de convocatoria del comicio y los asuntos a tratar (praecones); los ujieres o alguaciles (accensi), etc.⁽¹⁷⁾.

VIII. LAS OTRAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS⁽¹⁸⁾

1. El Senado

Es la asamblea política consultiva por excelencia. Los magistrados acuden permanentemente a él en procura de opinión. Si bien sus consejos, denominados "senadoconsultos" (senatus consulta), no son obligatorios, tienen gran peso en la decisión y ánimo de los magistrados por cuanto significa, sin lugar a dudas, una verdadera e incuestionable decisión de carácter político, que es tomada muy en cuenta por quien lo convoca. Si a ello añadimos que es atribución del Senado disponer los recursos financieros de Roma, la brevedad en la función de los magistrados comparados con los senadores, que tienen carácter vitalicio y gran experiencia en el manejo de la cosa pública, evidentemente su presencia política es gravitante, a tal punto que vuelvo a afirmar que históricamente es la verdadera columna vertebral de Roma. Su composición varía sustancialmente con el paso del tiempo. Así, cuenta con trescientos miembros a comienzos de la República, seiscientos en tiempos de Sila, un mil doscientos bajo el poder del "divino Julio César". Está conformado esencialmente por los "padres de familia", incluyendo luego a los ex magistrados y ciudadanos relevantes⁽¹⁹⁾. Todos aquellos que tienen derecho a integrarlo figuran en la lista que el censor confecciona con los ciudadanos que cumplen satisfactoriamente con los requisitos necesarios del censo (lectus senatus) y libres de toda tacha. El Senado es convocado y presidido en tiempos normales por el cónsul o, en su defecto, por el pretor, y en épocas excepcionales por el dictador.

Le corresponde la dignidad de ejercer el cargo de "Príncipe del Senado" (princips senatus) al senador patricio de mayor antigüedad en el cargo, recayendo luego este honor en el ex censor de mayor antigüedad. El Príncipe del Senado es el primero en emitir su opinión o voto, con la suma importancia que esto conlleva, puesto que le permite orientar y dirigir las decisiones. Luego, el orden de la votación continúa con los ex censores, ex cónsules, ex pretores, ex ediles, ex tribunos, ex cuestores, cerrando el resto de los senadores. Debo recordar que durante la Monarquía, le corresponde al senador de mayor antigüedad el cargo extraordinario de interrex (rey interino) en caso de acefalía. Esto significa, en mi opinión, el paso más natural que conduce a la creación de la "super magistratura" encarnada por el Príncipe en el Alto Imperio.

Destaco también que al principio existe la diferenciación entre aquellos senadores de origen patricio (patres) y plebeyo (conscripti o pedarii). La diferencia estriba en que los primeros tienen mayor poder y predicamento que los últimos, evidenciado en que su condición le otorga voz y voto, mientras que los plebeyos sólo tienen voz. Más tarde ambos reciben la denominación común de patres conscripti cuando lentamente es aceptada legal y socialmente la "integración patricia-plebeya" tras la sanción de los plebiscitos Atinia y Ovinia (312 a.C.).

Finalmente, puedo señalar entre las principales funciones y atribuciones del Senado las siguientes: administra la hacienda pública; dispone del tesoro; maneja las relaciones exteriores; envía y recibe embajadores; representa al Estado en el extranjero; firma tratados de alianza; nombra jefes del ejército; adjudica premios y castigos a las tropas; regula y vigila el culto público y concede la aprobación a las decisiones comiciales (auctoritas patrum). Esta última facultad significa un gran poder de fiscalización política, dado que ninguna "ley rogada" entra en vigencia sin dicho

beneplácito. Luego, la aplicación de la auctoritas patrum se modifica, perdiendo importancia, puesto que debe concederse de modo previo al tratamiento de la ley en los comicios, y no una vez aprobada por éstos.

2. Los comicios

Continúan siendo por excelencia las asambleas representativas del pueblo romano. Durante la República se observa la declinación del viejo comicio por curias, el nacimiento pujante del comicio por centurias, y luego la aparición de los comicios por tribus y de la plebe. Estos últimos son producto aparente, como se dijera *ut supra*, de las reformas atribuidas a Servio Tulio.

2.1. Comicio curiado

Este antiguo tipo de comicios pierde sus atribuciones originarias cuando éstas les son trasferidas a los comicios centuriados o, en determinados casos, directamente suprimidas. Conservan sólo la aplicación de la *lex curiata*, por la cual se reviste de "imperio" a los magistrados elegidos por los comicios centuriados y otorga la posesión del cargo al jefe o rey sacerdotal (*rex sacrorum*). Avanzada la República, el pueblo no se reúne más en este tipo de asamblea, sino que es representado en ella mediante la presencia de treinta *lictors* asistidos por tres augures, restando la implementación de la *lex curiata de imperium* como un mero trámite.

2.2. Comicio centuriado

Adquiere importancia política inusitada durante la República, pues absorbe de hecho los poderes y atribuciones que posee el "comicio por curias", que, como se dijo, comienza a declinar. El comicio centuriado tiene atribuciones electorales, legislativas, judiciales y de relaciones exteriores.

Dentro de las facultades electorales, le compete la elección de los magistrados mayores, a saber, cónsul, pretor y censor. En uso de las atribuciones legislativas, dicta todo tipo de normas obligatorias (*lex rogata*) para los ciudadanos, como también las dispensas a éstos para su cumplimiento, otorga la ciudadanía, crea magistraturas y cargos sacerdotales, adjudica tierras estatales, etc. Judicialmente interviene cuando el ciudadano interpone la apelación contra la aplicación de la pena capital impuesta por un magistrado (*provocatio ad populum*). Respecto de las potestades referentes a las relaciones exteriores, declara la guerra y la paz (*lex de bello indicendo*) y firma tratados con otros pueblos.

2.3. Concilio de la plebe (*concilia plebis*)

Su origen es casi paralelo a los comicios tribados. Surge como necesidad plebeya de reunirse para resolver problemas de su clase y para elegir los magistrados que la representan (tribuno y edil plebeyo). Es convocado y presidido por el tribuno, y las decisiones que adopta tienen originariamente sólo obligatoriedad para la clase plebeya. Luego, ante el incremento de su importancia, estas decisiones, denominadas "plebiscitos" (*plebiscita*), adquieren fuerza de ley para todos los ciudadanos sin excepción con la sanción de la *lex Hortensia* (289 a.C.).

2.4. Comicio tribado

Es también de antigua data, aunque no se puede determinar con exactitud su inicio. Se acepta por lo general que nace tras la presión siempre constante de la clase plebeya, como una derivación del concilio de la plebe. Tiene facultades electorales, legislativas y judiciales.

Dentro de las facultades electorales designa a los magistrados menores (cuestor, edil) y más tarde reemplaza al concilio de la plebe en la elección de los tribunos y ediles plebeyos. En uso de las facultades legislativas, tras la sanción de la lex Hortensia, reemplaza por completo al "comicio centuriado" en la sanción de leyes de carácter general. Esto se debe al cambio de composición, dado que la antigua división en "centurias" es después mutada estructuralmente con la introducción de "las tribus", convirtiendo su integración en más popular. Es de destacar, sin embargo, que todo lo concerniente al manejo de las relaciones exteriores y la ley que impone de poder a los censores cada cinco años (lex de censoria potestae) continúa como atribución de los "comicios centuriados". Finalmente, el "comicio tribado" es competente en grado de apelación de las multas fijadas por los magistrados cuando ellas exceden el máximo previsto en las leyes Aternia Tarpeta (454 a.C.), Menenia Sextia (452 a.C.) e Iulia Papiria (450 a.C.).

IX. LAS PRINCIPALES FUENTES DE DERECHO⁽²⁰⁾

Las principales "fuentes de producción de derecho" durante este período son la "ley de las XII Tablas", principal y más importante de todas las leyes rogadas; la "ley rogada" (lex rogata) y el edicto del pretor.

1. Ley rogada (lex rogata)

Es la ley romana (lex) propiamente dicha. Gayo la define diciendo que "es lo que el pueblo manda, establece"⁽²¹⁾. Esto es así, por cuanto señalé ut supra que los juristas y políticos romanos consideran que el pueblo se encuentra representado en el comicio; por ende, ley (lex) únicamente es la emanada de dichas asambleas, ya sea en carácter de ley o plebiscito. Justiniano, por su parte, también brinda el concepto de ley, refiriéndola como aquella "que es sancionada, constituida, por el pueblo romano interrogado por un magistrado senatorial, como el cónsul"⁽²²⁾.

Sin ánimo de intensificar la cuestión, y dejando a salvo que ha sido motivo de preocupación de distintos juristas romanos definir la ley (v.gr., Papiniano, Marciano, Modestino, etc.⁽²³⁾), es menester dejar en claro que propiamente es considerada ley en sentido estricto la que emana de los comicios después del ruego solemne efectuado por un magistrado de carácter mayor (cónsul, pretor, etc.)⁽²⁴⁾.

El acto legislativo comienza al despuntar el alba, cuando un heraldo convoca al pueblo en el lugar adecuado, así el Campo de Marte en el caso de los "comicios centuriados", y en el Foro cuando se trata de los "comicios tribados", donde el magistrado invoca la protección de los dioses mediante un sacrificio, luego efectúa la lectura del texto de la ley que deberá ser sometida a votación y finalmente ruega su aprobación.

En un principio, la votación de la ley se realiza mediante voto oral, manifestándose simplemente "sí" o "no", y después se introduce el voto escrito mediante tablillas (lex Papiria, 131 a.C.). Estas tablillas les son entregadas a los ciudadanos que convergen al acto y en ellas sólo deben colocar la inicial que indica el sentido de su voto, a saber, "como lo pides" ("U.R." —uti roga—) o "contra lo que pides" ("A.Q.R." —anti quo rogas—). Una vez efectuado el recuento de votos, se da a conocer

públicamente el resultado de la votación y el magistrado clausura formalmente el acto (renuntiatio)⁽²⁵⁾.

La ley rogada consta de las siguientes tres partes: "prescripción" (praescriptio), "ruego" (rogatio) y "sanción" (sanctio). La "prescripción" contiene nombre y título del magistrado que la propone, día y lugar en que se vota, tipo de comicio que interviene y nombre del ciudadano que vota en primer término. El "ruego" es el texto íntegro de la ley. La "sanción" establece las consecuencias que trae consigo la inobservancia de la ley⁽²⁶⁾.

Dentro de "la ley rogada" debemos considerar también "el plebiscito" (concilia plebis), que consiste en "la ley aprobada por la plebe en su comicio a propuesta de un tribuno", y de lo cual hemos hablado ut supra⁽²⁷⁾.

2. Ley de las xii Tablas

Más arriba me he referido con amplitud respecto de la sanción de esta ley, que es capital por ser la primera de este tipo que se sanciona en Roma, y, a mi entender, la que origina el comienzo del "derecho escrito" como medio de "seguridad" y "permanencia". Esta ley, denominada también "decenviral", da comienzo escrito al "derecho quiritaro" o "civil" (ius civile) que contempla el derecho de los ciudadanos romanos y, por tal motivo, es conservadora, dura y estrictamente formalista. En contraposición a ella, como se ha visto, comienza a enarbolarse el "derecho honorario", producto cotidiano de la labor de los magistrados mayores, esencialmente el pretor, que suaviza, acota, humaniza, adecua el vetusto "derecho quiritaro", tornándolo proclive a la realidad y actualizándolo al momento que les toca en turno vivir. Esto lo logra el pretor mediante la actividad interpretativa (interpretatio)⁽²⁸⁾.

2.1. Texto de la ley de las XII Tablas

A continuación transcribo la que considero la versión más aceptada por la generalidad de la doctrina, aunque con variedad en pequeños matices⁽²⁹⁾, destacando, asimismo, que en nuestro país el romanista Mario Mojer ha efectuado hace pocos años una nueva y excelente traducción de su texto⁽³⁰⁾.

Tabla I: De la comparecencia ante el magistrado (in ius vocando)

1. Si se cita alguno ante el magistrado y se niega a ir, toma testigos y deténle. 2. Si se busca evasivas o trata de huir, échale mano. 3. Si se halla impedido por la enfermedad o por la edad, que el que le cita ante el magistrado le suministre medio de transporte, pero no un carro cubierto si no es benévolamente. 4. Que para quien tenga bienes sólo otro que los posea sea garante, mas para un proletario, sea garante cualquiera. 5. Si transan, pronuncia el acuerdo. 6. Si no hay transacción, que se exponga la petición antes del mediodía en el Comicio o en el Foro contradictoriamente entre las dos partes litigantes, si se hallan presentes. 7. Después del mediodía que el magistrado adjudique el proceso a la parte que se halle presente. 8. Que la puesta del sol sea el término supremo de todo acto del procedimiento. 9. Trata de las garantías procesales que aseguran la comparecencia del demandado ante el magistrado.

Tabla II: De las instancias judiciales (de iudiciis)

1. Disposiciones acerca de la suma a que podía ascender la consignación llamada sacramentum que debían depositar las partes. 2. Trata de los motivos justificatorios (grave enfermedad) para que el juez o árbitro aplaze el día de la audiencia. 3. Aquel que necesite el testimonio de alguno vaya por tres días delante de su puerta a hacerle en alta voz la intimación. 4. Disposición que permite transigir hasta sobre el robo.

Tabla III: De la ejecución en caso de confesión o condenación (de aere confeso rebusque iuri iudicati)

1. Si el deudor es confeso o el litigio ha sido legítimamente juzgado, concédase al deudor un plazo legal de treinta días. 2. Después de los treinta días tenga lugar contra él la aprehensión corporal y que sea conducido ante el tribunal. 3. Si no cumple la sentencia o no se presenta alguien como fiador ante el tribunal, que el acreedor le lleve a su casa, le encadene y le ponga correas o cadenas en los pies que no pesen más de quince libras y de ahí abajo en voluntad. 4. Si quiere viva de lo suyo, si no que el acreedor que le ha mandado encadenar le suministre diariamente una libra de harina o más si quiere. 5. Después del tercer día de mercado que le partan en pedazos, si cortan partes más o menos grandes, que no haya en ello fraude.

Tabla IV: Del poder del padre de familia (de iure patrio)

1. Disposición a la obligación de matar a los hijos deformes o monstruosos. 2. Disposición relativa al poder del padre sobre sus hijos, que le da derecho a venderlos o matarlos así como a encerrarlos, azotarlos o tenerlos encadenados, aun cuando desempeñen elevados cargos de la República. 3. Si el padre ha vendido tres veces a su hijo, sea el hijo libre de la potestad paterna. 4. Disposición que fija en diez meses el mayor término de duración de la gestación.

Tabla V: De las herencias y de las tutelas (de hereditatibus et tutelis)

1. Disposición relativa a la tutela perpetua de las mujeres, con excepción de las vestales. 2. Disposición que prohíbe la usucapión de las res mancipi pertenecientes a las mujeres colocadas bajo la tutela de sus agnados, a menos que las hubiere entregado contra la autorización de su tutor. 3. Lo que el difunto hubiera dispuesto en su testamento acerca de sus bienes y sobre la tutela de los suyos, sea tenido por derecho. 4. Si muere intestado el que carece de un heredero forzoso, tenga la herencia el agnado más próximo. 5. Si no hay agnado tengan la herencia los gentiles. 6. Disposición que consagra que los agnados y los gentiles son tutores legítimos a falta de tutor testamentario. 7. Si alguien es furioso y no tiene curador, recaiga sobre él y sobre su patrimonio la potestad de los agnados y los gentiles. 8. Disposición que confiere al patrono la herencia del liberto que muere sin heredero forzoso. 9. Disposición que consagra que si son varios los herederos llamados, las deudas y los créditos deben dividirse de pleno derecho en proporción a las partes hereditarias. 10. Disposición relativa a la acción de partición de la herencia. 11. Disposición por la que el esclavo manumitido por testamento bajo condición de entregar una suma al heredero, puede si el heredero lo enajena, adquirir la libertad satisfaciendo la referida cantidad a su comprador.

Tabla VI: De la propiedad y de la posesión (de dominio et possessione)

1. Cuando alguien efectúe las solemnidades de la mancipación, sea derecho lo que declare. 2. Disposición que establece la pena del duplo al que negara las declaraciones hechas en el nexum o mancipium. 3. Que la adquisición de la propiedad por la posesión sea de un bienio para los fundos y de un año para todas las demás cosas. 4. Disposición relativa a la adquisición del poder marital sobre la mujer por la posesión de un año y sobre la facultad concedida a la misma de interrumpir ese efecto ausentándose cada año tres noches consecutivas del domicilio conyugal. 5. Frente al peregrino la posesión de una cosa perteneciente al ciudadano tiene eterna garantía. 6. Disposición que prohíbe usucapir la cosa robada. 7. Disposición que prohíbe usucapir un sepulcro. 8. Disposición que prohíbe usucapir el espacio que debe dejarse libre entre los edificios o campos contiguos. 9. Si quienes comparecen ante el tribunal debaten sobre la propiedad de una cosa, que el Magistrado dé la posesión provisional a quien juzgare conveniente. 10. Disposición que establece que tratándose de un proceso de libertad, el Magistrado debe dar siempre la posesión provisional a favor de la libertad. 11. La viga incorporada a un edificio, el palo unido a la vid, no sean separados. 12. Disposición relativa a la acción del doble que se acuerda al propietario de los palos y de las vigas cuando no pueda obtener la separación. 13. Cuando la viña haya sido podada o se hubieran quitado palos y vigas de un edificio, el propietario puede reivindicarlos. 14. Disposición que establece que la propiedad de una cosa vendida y entregada no es adquirida por el comprador hasta que no ha pagado el precio al vendedor.

FRANJA

Tabla VII: Derecho en cuanto a los edificios y las heredades (de iure aedium et agrorum)

1. Disposiciones relativas a la obligación de dejar cierto espacio para la circulación entre los edificios y los campos inmediatos, de dos pies y medio y cinco pies respectivamente. 2. Disposiciones referentes a los espacios que deben respetarse en las construcciones o excavaciones hechas en un fundo o heredad inmediata a otra. 3. Disposición que establece que la amplitud de la servidumbre de paso (vía) debe ser de ocho pies en las rectas y de dieciséis en las curvas. 4. Si las partes están discordes sobre los lindes, el Magistrado debe nombrar tres árbitros para que decidan. 5. Si la vía está garantizada por los propietarios vecinos, pase por donde quiera con su juramento. 6. Si el agua pluvial causa daños por efecto de una obra hecha por el vecino, el propietario tiene acción para conseguir la restitución al primitivo estado. 7. Disposición que consagra la obligación de cortar las ramas que penden sobre el fundo vecino hasta la altura de quince pies. 8. Disposición acerca del derecho del propietario de talar el árbol del vecino cuando se inclinare sobre el fundo propio. 9. Disposición relativa al derecho del propietario de recoger, en días alternos, los frutos caídos en el fundo del vecino.

Tabla VIII: De los delitos (de delictis)

1. Disposición que establece pena capital contra los autores de libelos y ultrajes públicos difamatorios. 2. Contra el que rompe un miembro y no transige, la pena del Talión. 3. Si con la mano se fracturó un hueso a un hombre libre, sufra la pena de trescientos ases, si a un esclavo, de ciento cincuenta. 4. Por la injuria hecha a otro, pena de veinticinco ases. 5. Por el daño causado injustamente, la reparación. 6. Disposición que otorga la acción noxal al ofendido por el hurto cometido por el esclavo o el hijo de familia. 7. Disposición que da acción por los daños causados por un animal contra su propietario. 8. Disposición relativa a la acción que se da contra el que introduce a pastar su ganado en terreno ajeno. 9. El que con encantamientos eche a perder las cosechas o las traslade de un campo a otro, sea castigado. 10. Disposición que castiga al que de

noche y furtivamente siegue las mieses o la dé como pasto a los animales con pena de muerte con expiación a Ceres, si es púber, y con flagelación y pago del doble del daño, si es impúber. 11. Disposición que condena el incendio de casas o gavillas con pena capital si se lo hace a sabiendas, con resarcimiento del daño si se lo hiciere por descuido y moderadamente, si el autor es demasiado pobre para pagar la indemnización. 12. Disposición que castiga la tala de árboles ajenos con pena de veinticinco ases por cada uno. 13. Si alguno fuese muerto al cometer de noche un robo, lo será con justicia. 14. Disposición que prohíbe matar al ladrón sorprendido durante el día, sin antes haber pedido socorro, salvo que se resistiere con armas. 15. Disposición que condena el hurto manifiesto con pena de flagelación y entrega a la víctima, si el ladrón es libre y púber; con flagelación y composición, si es impúber, y si es esclavo, debía ser azotado con varas y precipitado a la roca Tarpeya. 16. Si se intentara acción por un hurto no manifiesto, que la pena contra el ladrón sea del duplo. 17. Disposiciones que sancionan con pena del triple al hurto no manifiesto cuando se trata del *furtum conceptum* y *oblatum* y que lo equiparan al hurto manifiesto cuando se realizara la pesquisa solemne del lance *licioque*. 18. Disposición que castiga al prestamista cuando cobra por el dinero que ha prestado un interés superior a una onza por ciento al mes, estableciendo la pena del cuádruplo. 19. Disposición que sanciona al depositario infiel con pena del doble. 20. Disposición que faculta a cualquier ciudadano para hacer separar de la tutela a los tutores testamentarios que se han hecho sospechosos. Pena del doble al que se hubiera apropiado de los bienes del pupilo. 21. Que el patrono que defraude a sus clientes sea sacrificado a los dioses. 22. Quien haya actuado como testigo en un acto o *comolibripens*, si se niega a dar testimonio, sea declarado incapaz para ser testigo e indigno de que se atestigüe por él. 23. Disposición que ordena que el testigo falso sea precipitado desde la roca Tarpeya. 24. Disposición que condena al homicida con pena capital. 25. Al que haya sujetado a alguno con palabras de encantamiento, pena capital.

Tabla IX: Del derecho público (de iure publico)

1. Disposición que consagra la prohibición de proponer leyes acerca de personas determinadas. 2. Disposición relativa al exclusivo derecho de los Comicios por Centuria para dictar decisiones capitales referentes a los ciudadanos. 3. Disposición que sanciona con la pena de muerte al juez o al árbitro que haya recibido dinero para pronunciar sentencia. 4. Disposición concerniente a la competencia de los *quaestores parricidii* en las causas capitales. 5. Disposición relativa a la competencia de los comicios centuriados para entender en grado de apelación contra las sentencias capitales. 6. Disposición que establece la pena de muerte contra el que hubiera excitado al enemigo contra el pueblo romano o hubiera entregado a un ciudadano al enemigo.

Tabla X: Del derecho sagrado (de iure sacro)

1. Ningún muerto puede ser enterrado ni quemado en la ciudad. 2. Disposición que trata sobre el modo de tratar la limpieza de los cadáveres. 3. Disposición que restringe las suntuosidades funerarias. El cadáver no podrá ser sepultado ni quemado con más de tres vestidos o de tres fajas de púrpura, ni acompañado con más de diez flautistas. 4. Que las mujeres no se arañen las mejillas ni lancen quejidos por causa de los funerales. 5. No recojáis los huesos de los muertos para hacerles nuevo funeral, salvo a los que murieron en el combate o en el extranjero. 6. Disposición que prohíbe las unciones serviles, las libaciones, coronas, vasos de ungüento y pociones de mirra en los funerales. 7. Quien por sí mismo, por sus esclavos o por sus caballos ha conquistado una corona, que le sea permitido llevarla en sus funerales. 8. Disposición que prohíbe celebrar muchos funerales y levantar varios túmulos por un solo muerto. 9. El cadáver no debe ser enterrado con oro, mas si alguno tuviese sus dientes ligados con oro y lo sepultasen o quemasen con ellos, no haya perjuicio. 10. Disposición que prohíbe colocar ninguna pira ni sepulcro a menos de sesenta pies del edificio de otro.

Tabla XI

1. Disposición que prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos.

Tabla XII

1. Disposición que establece la toma de prenda contra el deudor que no ha cumplido su obligación de pagar lo debido con motivo de un sacrificio ofrecido a los dioses.
2. Disposición que prohíbe hacer consagrar a los dioses una cosa litigiosa.
3. Disposición que establece que las últimas leyes del pueblo derogan a las anteriores⁽³¹⁾.

3. Edicto del pretor

La labor cotidiana del pretor es recogida en esa magnífica obra jurídica que se da en llamar justamente "Edicto del Pretor". Consiste en el "trabajo jurídico", paulatino, de sucesivos pretores que, al iniciar el año de mandato, confirman el "Edicto" de sus predecesores, introduciendo luego modificaciones al mismo, de ser necesario.

El "Edicto" consta de dos partes medulares denominadas "traslaticia" y "nueva". La primera, también denominada "residual", contiene el derecho considerado inalterable, aceptado por casi todos regularmente. La segunda, llamada también "innovadora", recoge las novedades introducidas por el pretor en turno. La "labor jurídica" de éste, destinada a "crear nuevo derecho", se produce por distintos medios, así, la "denegatoria de una acción" (denegatio actionis), "concesión de excepciones" (exceptionis), "creación de nuevas acciones" (como las denominadas genéricamente "ficticias"), "remedios pretorios" (v.gr. estipulaciones, interdictos, etc.). Finalmente he de decir, ratificando lo manifestado ut supra, que el mejor derecho de Roma se origina en la labor creativa del pretor, lo que sin lugar a dudas "da inicio al derecho privado del mundo occidental".

De manera sucinta, la actividad del pretor en el "proceso civil romano" consiste en regularlo y dirigirlo, otorgando una "acción" (actio) al litigante que acude a él frente a una controversia a los efectos de "legitimar" su reclamo y poder integrar a la otra parte a la litis. Si la acción existe, ya sea porque ha sido creada anteriormente por ley (lex) o por otro pretor, el acto es en sí mismo simple, de mero trámite. Mas si ella no existe, el pretor tiene la facultad de "crearla", si lo considera necesario, fundándose en la "equidad" (aequitas). Es aquí donde radica el numen de la importancia de la actividad del pretor que puede legítimamente, por las facultades que le competen en virtud del orden constitucional romano, "crear una acción", "dotar de una acción al litigante cuyo reclamo considera razonable" y así "legitimarlo procesalmente" para "estar a derecho". Por supuesto que esto no implica que éste "tenga la razón" y que haya vencido de hecho el pleito, sino que se encuentra facultado a iniciarlo, llevarlo adelante contra el demandado, correspondiendo en la segunda etapa del proceso resolver la cuestión al juez (iudex), árbitro (arbitrator) o tribunal mediante el dictado de la sentencia.

Las acciones creadas por los pretores, como he señalado más arriba, han sido recogidas en el citado "Edicto del Pretor", que es compilado luego por el gran jurista Salvio Juliano por orden del príncipe antonino Adriano. Esta recopilación, imbuida en la concentración del poder en manos del príncipe, le da un toque de muerte a la actividad creativa del pretor, por cuanto ya no puede "crear derecho", sino sólo aplicarlo, en virtud de que el único que puede hacerlo o introducir modificaciones al "Edicto" es el propio príncipe por medio de la oratio.

X. DERECHO DECENVIRAL. DERECHO CIVIL. DERECHO HONORARIO. DERECHO DE GENTES

Entiendo que en esta parte de la obra es menester detenerme en la distinción de "derecho decenviral" (quiritario), "derecho civil" (ius civile), "derecho honorario" (ius honorarium) y "derecho de gentes" (ius gentium).

En mi opinión, considero la denominación de "derecho quiritario" solamente al derecho de aplicación reservado para los ciudadanos romanos con exclusión de los extranjeros, que proviene de la costumbre y de la ley de las XII Tablas; no es otra cosa que el verdadero derecho de los ciudadanos romanos (quirites).

El "derecho civil" (ius civile) es también el establecido únicamente para las relaciones de los ciudadanos romanos con exclusión de los extranjeros, que proviene de la costumbre y de la ley escrita (ius scriptum), abarcando todas las fuentes, en general, que se suceden en la evolución del derecho romano, así, leyes rogadas, plebiscitos, senadoconsultos, constituciones imperiales, respuestas de los juristas, etc.⁽³²⁾.

El "derecho honorario o pretoriano" (ius honorarium o praetorium) es el originado por la actividad jurídica de los magistrados que gozan del ius edicendi, especialmente el pretor, que ayudan, suplen, corrigen el derecho civil⁽³³⁾ con el propósito de adecuarlo y humanizarlo, equipando las situaciones injustas e integrando a los postergados del viejo sistema legal defendiendo al más débil. Es el verdadero logro evolutivo del derecho romano.

El "derecho de gentes" (ius gentium) es el derecho común a todos los pueblos. El derecho romano tiene acceso a él por intermedio de la actividad de la pretura peregrina, creada en el año 242 a.C. para intervenir en los conflictos suscitados entre ciudadanos romanos y extranjeros o éstos entre sí. El constante crecimiento de Roma debido al auge del comercio y las conquistas militares hace que la interacción con los pueblos convergentes origine nuevas relaciones jurídicas que el "derecho civil" no puede absorber o solucionar en razón de su excesivo rigorismo y formalismo. Es evidente que el logro evolutivo del derecho romano arriva a su punto máximo, por cuanto, mediante la injerencia del pretor peregrino accede a las mejores soluciones jurídicas que presenta la comunidad de gentes, que luego son transportadas al tráfico jurídico romano, constituyendo parte del "derecho honorario".

XI. OBRAS JURÍDICAS POSTERIORES A LA LEY DE LAS XII TABLAS

La sanción de la ley de las XII Tablas constituye el paso más avanzado hacia la consolidación de la organización romana, marcando un hito histórico inigualable. No obstante, el patriciado romano continúa un tiempo más monopolizando el "quehacer jurídico". Por ello hallamos, después de la sanción de la ley decenviral y hasta que los pretores se afiancen en su misión de "crear derecho", las siguientes obras jurídicas de importancia.

En primer lugar, el ius flavianum (304 a.C.), cuyo autor es Cneus Flavius, publicación que contiene las acciones y demás actos procesales que los litigantes deben tener en cuenta para hacer valer su derecho. Aproximadamente cien años después, otro jurista, Sextus Aelius Paetus Catus, publica otra obra que también contiene las principales acciones y actos procesales, pero debidamente actualizados, que recibe el nombre de ius aelianum⁽³⁴⁾.

También en este mismo tiempo aparece otra obra denominada Tripertita, atribuida asimismo a este último jurista, conformada por tres partes esenciales, a saber: el texto de la ley de las XII Tablas, su comentario o interpretación y las acciones de la ley. La Tripertita tiene el inmenso valor no sólo de transcribir la ley decenviral, sino también de constituir el primer trabajo doctrinario sobre ella.

XII. LOS ÚLTIMOS TIEMPOS DEL PERÍODO REPUBLICANO. LA "CRISIS DEL SISTEMA"(35)

El período republicano de gobierno, que tanto éxito político e institucional le proporciona a Roma, lentamente comienza a entrar "en crisis". Resulta necesario detenernos, aunque brevemente, en el desarrollo de esta etapa para comprender mejor el nacimiento del nuevo período denominado "Imperio". La descomposición del sistema republicano y el nacimiento de sus mismas entrañas del nuevo orden constitucional, puedo agruparlo en dos tipos de causas: por un lado, las de tipo "socioeconómicas"; y por el otro, las "político-institucionales".

1. Causas "socioeconómicas" de la desintegración republicana(36)

Se originan una vez finalizada la integración patricio-plebeya. Esta gran lucha de clases protagonizada por patricios y plebeyos comienza con la supremacía pura y exclusiva de los primeros en todos los órdenes de la vida institucional y política de Roma, y el lento e inexorable camino iniciado por los plebeyos hasta alcanzar la equiparación. Este derrotero abarca aproximadamente trescientos años y comienza, según mi juicio, en las postrimerías de la Monarquía, con las discutidas reformas atribuidas al rey etrusco Servio Tulio, que permite el acceso de los plebeyos a los comicios. Luego, en el año 445 a.C., la lex Canuleia (lex rogata a propuesta del tribuno C. Canuleius) permite el matrimonio entre patricios y plebeyos en contra de lo dispuesto hasta ese momento por la ley de las XII Tablas. Más tarde, en el año 367 a.C., la lex Licinia Sextia (plebiscito votado a propuesta de los tribunos Licinius Stolo y Sextius Lateranus) dispone que el segundo cónsul puede ser de origen plebeyo. De modo implícito, esta ley permite a los plebeyos el acceso al Senado. A continuación, en el año 300 a.C., la lex Ogulnia de Sacerdotiis (lex rogata a propuesta de los tribunos Ogurnios) eleva el número de sacerdotes augures de cuatro a ocho, y el de los pontífices de cuatro a nueve, permitiendo a los plebeyos acceder a aquéllos por vez primera. Éste fue el caso de Tiberio Coruncanio, primer plebeyo nominado pontífice máximo. Por último, en el año 287 a.C., la lex Hotensia de Plebiscitis (lex rogata votada a propuesta del dictador Quintus Hotensius) concede a las decisiones plebeyas emanadas de los "plebiscitos" (concilia plebis) carácter de ley con aplicación obligatoria tanto para patricios como plebeyos.

Mas una vez concretada la integración patricio-plebeya, ello no significa, en rigor de verdad, el final de la división de clases, sino, por el contrario, el nacimiento de una nueva dicotomía social. La sociedad romana se ve escindida lentamente en la dualidad "óptimos-populares" (optimates-populares).

La puja entre patricios y plebeyos queda superada con la aparente igualdad alcanzada por estos últimos, pero igualmente los descendientes de la clase más pudiente (patricios) se perfilan mediante un desprendimiento de sus integrantes hacia una clase especial, distinta a la igualdad proclamada.

De tal modo surge la clase de los "óptimos" o "buenos" (optimates), que se consideran de tal modo por representar a la clase alta y poseer la mejor influencia a nivel político, además de acumular riquezas. Se dividen en "senatoriales" y "caballeros". Los primeros ("senatoriales"), denominados también "nobles", son los descendientes de las antiguas familias romanas cuyos antepasados han formado parte del Senado y las magistraturas. Por lo general, cobijan el poder y las influencias políticas. Los "caballeros" tienen origen en familias no tradicionales nacidas después de la fundación de Roma. Ostentan en su haber la acumulación de riquezas. Habrá que aclarar que la división no es tajante, puesto que coexisten "senatoriales" con influencias y riquezas e igualmente "caballeros" en similar situación. Lo cierto es que entre ambas clases conjugan "un verdadero factor de poder", puesto que aúnan "lo político y lo económico".

Por su parte, los "populares", si bien mayoritarios, son ajenos a la clase anterior y sus divisiones, puesto que carecen de riquezas e influencias. Conforman el estrato más bajo de la población.

1.1. Los hermanos Graco(37)

Dentro de las causas "socioeconómicas" tenemos que considerar la irrupción de los hermanos Graco. Primero, Tiberio Sempronio Graco, nominado tribuno en el año 133 a.C.; y segundo, Cayo Sempronio Graco, también elegido tribuno en el año 123 a.C. Ambos, fieles exponentes de la lucha entre "optimates" y "populares", defienden los derechos de estos últimos, lidiando contra los intereses de los primeros. Los hermanos Graco pertenecen a la antigua familia de los Sempronios, caracterizada familia noble de origen plebeyo.

1.1.1. Tiberio Sempronio Graco

En el año 133 a.C., Tiberio es electo tribuno, llevando a cabo para ello una campaña política mediante una apasionada defensa de "la reforma agraria" con el propósito de obtener la reconstrucción de la pequeña propiedad agrícola en Italia, destruyendo los latifundios, lograr una mejor situación para los trabajadores libres, mejorar el ejército y sanear la vida política de las asambleas comiciales. Es decir, privilegiar la situación de la clase "popular" en desmedro de los "óptimos".

La ley de Tiberio consta de tres puntos básicos: 1º) Amplía la vieja norma de Licinio y Sextio por la cual a cada poseedor de tierra estatal (ager publicus) se le permite mantener en propiedad sólo 500 yugadas, concediéndosele además, en caso de que tuviera hijos, 250 yugadas por cada uno de ellos, con la limitación de 1.000 yugadas en total de tierra estatal por cada familia (aproximadamente 250 hectáreas actuales); 2º) Establece que la tierra estatal sobrante debe ser restituida al dominio público, quien se encarga de redistribuirla en pequeñas parcelas de 30 yugadas cada una a los ciudadanos pobres en arriendo hereditario, con la condición esencial de que no pueden enajenarlas; 3º) Crea una comisión especial de tres personas con plenos poderes, destinada a ocuparse de llevar a cabo la reforma agraria (triunviri agris iudicandis adsignandi).

Obviamente, esta "ley agraria" afecta los intereses de los "óptimos", únicos poseedores de considerables extensiones de tierra estatal, que actúan como sus verdaderos propietarios, prescindiendo del Estado, quien es en verdad el legítimo propietario. Y esto es tan así que incluso transmiten por herencia la posesión de las tierras, construyen muros, cercados y realizan otras actitudes reservadas exclusivamente a los propietarios.

Al mismo tiempo, Tiberio tiene en mente otros proyectos revolucionarios, como ser: disminución del tiempo de prestación de servicio militar; derecho de apelación al pueblo contra las sentencias judiciales; equiparación de patricios y plebeyos en el nombramiento de los colegios judiciales; concesión de los derechos de ciudadanía a latinos y aliados de Roma. Pero lamentablemente estos proyectos no pueden concretarse por los acontecimientos turbulentos que le cobran la vida. Su asesinato está rodeado de hechos singulares que lo convierten en un mártir inolado en defensa de los intereses de los más pobres (populares) contra la clase verdaderamente alta e influyente (óptimos).

1.1.2. Cayo Sempronio Graco

En el año 123 a.C., el menor de los Graco (Cayo) es electo tribuno por primera vez y propone la sanción de tres leyes fundamentales, a saber: ley agraria (lex agraria); ley sobre el trigo (lex frumentaria) y ley judicial (lex iudiciaria).

Estas leyes son parte fundamental de la reforma introducida por Cayo dentro de la sociedad romana, persiguiendo la equiparación de la clase "popular" con la de los "óptimos", por cuanto no sólo persigue profundizar la reforma agraria iniciada por su hermano, sino también poner al alcance del pueblo la adquisición del trigo mediante la regulación de su precio. Además intenta lograr, mediante la reforma judicial, mejorar la defensa de los derechos de los menos pudientes. También propone la sanción de otras leyes como complemento de las anteriores, así, la ley militar (lex militaris); la ley sobre construcción de calles (lex de viis muniendis); la ley sobre las provincias consulares (lex de provinciis consularibus), etc.

Una vez consolidado en el poder mediante la reelección del año 122 a.C., Cayo se dispone a lograr la sanción de dos nuevas leyes de suma importancia para afianzar definitivamente las reformas iniciadas; una es la "ley sobre el establecimiento de las colonias" (lex Sempronia de coloniis deducendis); y la otra, la ley sobre la concesión de derechos de ciudadanía a los habitantes de Italia. Lamentablemente, Cayo, al igual que su hermano, también es asesinado por oponerse a los intereses de la clase alta gobernante (óptimos).

Los hermanos Graco son fieles exponentes de una vigorizada lucha de clases que les cuesta la vida. Sus muertes, fagocitadas en el fragor de la controversia social, son claro indicio de que el sistema republicano de gobierno comienza a declinar y que un nuevo orden pronto ha de nacer.

2. Causas "político-institucionales" de la desintegración republicana(38)

Su origen se sitúa aproximadamente en los últimos cien años del sistema republicano de gobierno. Cada vez más asiduamente el orden constitucional "ordinario" romano es reemplazado por el de "excepción" mediante la irrupción dentro del sistema de los "caudillos" o "dictadores" que preanuncian el nacimiento de una nueva forma de gobierno. La presencia recurrente de estos "magistrados extraordinarios" se debe, entre otras razones, a las guerras intestinas que convulsionan Roma, el aumento de la clase "popular" conculcada por los "óptimos", la beligerancia creciente de las etnias vencidas que, al advertir los problemas institucionales de Roma, pretenden obtener ventaja, intentando reconquistar sus antiguos territorios. Dentro de este contexto se suscitan los acontecimientos que fundamentan el período con el propósito de solucionar los conflictos mencionados.

2.1. Cayo Mario

Es elegido cónsul en el año 100 a.C. Siendo un excelente militar de origen plebeyo que pronto se erige en defensor y jefe de la clase "popular", organiza profesionalmente al ejército, derrota de modo contundente al rey Yugurta y a los cimrios y teutones, enemigos tradicionales de Roma. El respeto alcanzado por Mario en virtud de sus conquistas militares y modo férreo de gobernar hace que ocupara varias veces el consulado. Si bien en un principio enarbola la defensa de la clase "popular", luchando decididamente contra los "óptimos", luego vira su inclinación, seducido por estos últimos, traicionando a los primeros.

TRANSIA
MORADA

2.2. Lucio Cornelio Syla

El ocaso de Mario, caracterizado por su apego a la bebida y sus excesos en el poder, es capitalizado por Syla, de origen patricio y fiel exponente de los "óptimos", de personalidad astuta, fría y despiadada. Syla se erige en principio dentro del poder republicano avalado por Mario, de quien aprende la organización militar, dado que es su lugarteniente e incluso cuñado, y el modo de gobernar, aunque luego no duda en traicionarlo. Es electo cónsul en el año 90 a.C., implantando largas listas de proscripciones y persecuciones, no sólo políticas sino también económicas. Dentro de sus campañas militares se encuentran las extensas y costosas luchas contra Mitriades, rey del Ponto. Más tarde es nombrado "dictador perpetuo", encargado de redactar leyes y organizar la constitución (82 a.C.). Con esto último la República se encuentra a un paso del sistema imperial.

2.3. El conflicto social en la Península Itálica(39)

Trato especial merece la cuestión del conflicto social extendido a la Península Itálica durante el período de hegemonía protagonizados por Mario y Syla, que motiva la unión y alianza de los pueblos que la habitan en una "confederación" denominada "Italia", siendo la primera vez que se emplea este nombre, con capital en la ciudad de Corfino. Esta lucha entre Roma y los pueblos itálicos finaliza con un tratado por el cual se les concede "la ciudadanía a todos los habitantes de la Península Itálica" en tiempos de Syla.

2.4. Cneo Pompeyo

Cuando Syla abandona el poder abdicando, su yerno Cneo Pompeyo se convierte circunstancialmente en el hombre fuerte de Roma (80 a.C.). Es un talentoso militar de carrera, bien considerado por sus soldados, que derrota una vez más al mítico rey Mitríades, que pasa su larga vida enfrentando a Roma; aniquila a Espartaco y su poderoso levantamiento de esclavos, y sofoca la rebelión de Catilina.

2.5. Licinio Craso

Junto a Pompeyo aparece en la escena política de Roma el general y acaudalado terrateniente Licinio Craso, perteneciente a la clase de los "óptimos". Ambos conforman una alianza política y alcanzan el consulado en el año 70 a.C.

2.6. Cayo Julio César

Contemporáneamente a Pompeyo y Craso, comienza su brillante carrera política uno de los estadistas más grande de la Antigüedad: Cayo Julio César. En mi opinión, la actuación política del "divino Julio César", así se lo conoce, origina un nuevo sistema de gobierno, dando nacimiento definitivamente al imperio. Su familia pertenece a la gens Julia, una de las más antiguas y prestigiosas de Roma, cuyo origen se remonta a la unión del rey Anco Marcio con la diosa Venus. Muy pronto César comprende, pese a que su familia forma parte de la clase de los "óptimos", evidenciando fino instinto político, que el verdadero desafío consiste en erigirse en conductor de la clase "popular" siguiendo los pasos de los hermanos Graco. Así lo lleva a cabo y es endiosado por el pueblo. De personalidad avasallante, cautivadora, seductora, es portador de un aura mítica y carismática que le permite gobernar en uso de todas las facultades que el pueblo romano confía ciegamente en sus manos. Se revela como eximio estratega militar, brillante político, historiador, escritor e incluso legislador, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de la historia antigua. Su figura política encarna el fin del moribundo sistema republicano de gobierno y el nacimiento del nuevo gobierno imperial. Su brillante actuación política, respaldada en su gran influencia sobre la clase "popular", lo erige en claro e insoslayable referente del poder.

2.6.1. El primer triunvirato político(40)

En el año 60 a.C., César, Craso y Pompeyo formalizan una "alianza político-militar" que se conoce como "primer triunvirato", en el cual el primero es estadista, el segundo capitalista y el último militar. Poco después la historia coloca las cosas en su lugar y el "divino Julio César" se convierte en el único protagonista político y militar de Roma. César inicia su brillante carrera militar mediante la conquista de las Galias, al derrotar al rey Vercingetorix en la batalla de Alesia (52 a.C.). Las incipientes disputas internas dentro del "triunvirato" en procura de mayor espacio de poder se agudizan tras la inesperada muerte de Craso, cuando se encuentra en campaña militar contra los partos. En realidad, los roces y enfrentamientos entre César y Pompeyo se hacen notorios debido a la incontinente trayectoria política del primero y la merma lenta e inexorable del segundo. Únicamente Craso los mantiene unidos valiéndose de su poder de persuasión sobre ambos. Incluso César entrega en matrimonio a su hija Julia a Pompeyo, a quien admira y considera. Pero una vez muerto Craso, y divorciado Pompeyo de Julia, el enfrentamiento entre ambos se torna inevitable.

En rigor de verdad, César y Pompeyo representan las clases sociales en disputa por el poder. El primero es el abanderado de los "populares", mientras el segundo lo es de los "óptimos", que

observan con particular temor y encono la figura de César. Así, encontrándose éste aún en las Galias, Pompeyo intenta convertirse en el único gobernante de Roma con el apoyo mayoritario de los "óptimos", lo cual produce que el enfrentamiento entre ambos no tenga posibilidad de retorno al desoír Pompeyo los cuestionamientos y razonamiento de César. Entonces, este último decide transgredir el principio constitucional que impide marchar con las legiones hacia Roma, cruzando el límite jurisdiccional militar de su territorio, el riachuelo Rubicón, situado al norte de Rímini, exclamando la frase de su poeta favorito, Menandro: ¡Que ruede el dado! (amerríphtho kybos) que la historia ha recogido impropriamente traducida al latín como: "La suerte está echada" (alea iacta est)⁽⁴¹⁾. Pompeyo y los senadores que le son adictos, temerosos de César, pese a los mensajes apaciguadores enviados por éste, deciden abandonar la ciudad de Roma buscando refugio en Grecia. Desde allí continúan la hostilidad hacia César, lo que lo induce a enfrentarlos.

En primer lugar, César, con la intención táctica de debilitar a Pompeyo, se dirige a España para enfrentar a una parte del ejército que le es adicto a este último. Las legiones de Pompeyo se encuentran acantonadas al nordeste de Ilerda, al mando de sus generales fieles. Pero éstos capitulan al avistar el poderío militar de César. Luego, éste toma Marsella, finalizando así la resistencia pompeyana en España. Apaciguada la Península Ibérica, César decide mantener el encuentro decisivo con las fuerzas de Pompeyo situadas en Grecia. Los primeros combates no le son favorables, superado en número y avituallamiento, pero luego consigue derrotar a Pompeyo en las llanuras de Farsalia (48 a.C.), asegurando más tarde la victoria en las batallas de Tapso y Munda, en donde las disciplinadas y avezadas legiones de César logran una memorable victoria sobre las bisoñas fuerzas de Pompeyo. Desesperado, este último decidió buscar refugio en Egipto, donde se encuentra gobernando Ptolomeo, que, para congraciarse con César, decide ejecutarlo. El crimen no es del agrado de éste, que castiga a quienes lo ejecutan y destituye a Ptolomeo, tomando partido político por su hermana Cleopatra, erigiéndola en soberana y luego en su amante.

FRANJA

2.6.2. La obra de Julio César⁽⁴²⁾

Julio César brega en procura del mejoramiento de la clase "popular", especialmente el campesinado, disponiendo nuevas y equitativas distribuciones de tierras. También tiene en cuenta favorecer a las familias numerosas y ordena castigar el lujo desmedido. Propone la sanción de diversas leyes, a saber, organización de los tribunales de justicia (lex iudiciaria); mejoramiento del sistema penal (lex de vi y maiestatis); perfeccionamiento de la administración de las provincias (lex iulia provinciis). Además, crea un nuevo tipo de funcionarios (praefectus urbis), que toman parte de las facultades que antes les correspondían a pretores, cuestores y ediles.

2.6.3. Los poderes políticos de César y el nacimiento del nuevo sistema⁽⁴³⁾

Erígido César en el virtual único gobernante de Roma, recibe por parte del Senado y los comicios los más altos poderes, atribuciones y honores. Es designado "dictador perpetuo", vislumbrando así el tinte monárquico que poco tiempo después caracteriza al nuevo sistema. Se le confiere el título de imperator con derecho de transmitirlo a sus herederos; el mando de los ejércitos; el derecho de usar siempre las insignias del triunfo; la atribución de designar a los magistrados sin consulta previa a los comicios, y el derecho de acuñar moneda con su efigie. Además, se ve favorecido con el título de "divino protector de Roma" (iupiter iulio) y el derecho de colocar su busto entre las divinidades del Estado romano.

2.7. El segundo triunvirato político

Asesinado César en el año 44 a.C. por instigación de los "óptimos" en los "idus de marzo" (fiesta religiosa), se acelera el fin del período republicano y el paso al nuevo sistema imperial. La muerte abrupta de César trae consigo una situación de incertidumbre y revuelta popular, que es capitalizada ocasionalmente por Cayo Octavio, Marco Antonio y Lepido, que conforman una alianza política denominada históricamente "segundo triunvirato" (43 a.C.).

2.8. Marco Antonio

Ocupa el consulado al momento de la muerte de César y capitaliza políticamente su asesinato mediante una apesadumbrada y sentida oración fúnebre en favor de éste, propiciando el castigo de los culpables y llevando a cabo el reparto de dinero y víveres entre los más pobres.

2.9. Cayo Octavio

Es el descendiente natural y político de César, puesto que es su sobrino y heredero. Si bien hasta dicho momento mantiene un perfil bajo, comienza una rutilante carrera política que años después lo convierte en Augusto, primer príncipe del Alto Imperio.

2.10. Lepido

Reviste, al tiempo de la muerte de César, el cargo de lugarteniente de su ejército, jefe de su estado mayor y hombre de su entera confianza. Su presencia política es de importancia, porque representa a las avezadas legiones de César, a esta altura de los acontecimientos devenidas en insoslayable "factor de poder" a tener en cuenta en las decisiones.

2.11. El fin del período republicano. Primera división de Roma en Occidente y Oriente

El período histórico de la "crisis republicana", rico en matices, hechos y personajes, admite las siguientes lecturas: Marco Antonio comete el grave error político de instalarse fuera de Roma, en Alejandría, sometido por completo a los encantos de Cleopatra, cediendo el Senado de Roma al influjo de Octavio, originando lo que es, entiendo, la primera división, aunque de modo tácito, de Roma en Occidente y Oriente. Los personajes políticos de la época protagonizan anticipadamente, quizá premonitoriamente, la inevitable escisión futura del imperio. Octavio sabe capitalizar hábilmente los errores políticos de Marco Antonio con el Senado, prácticamente de su parte, fustigándolo mediante una sistemática campaña respecto de su exceso de lujo oriental, su caprichosa relación con Cleopatra, sus inoportunas manifestaciones de querer trasladar la capital del Estado a Alejandría en detrimento de Roma. Finalmente, Octavio consigue que el Senado le declare la guerra a Marco Antonio y Cleopatra. Las fuerzas de Roma, bajo el mando de Octavio, y las de Marco Antonio, compuestas por tropas propias y egipcias, sostienen la crucial batalla naval de Actium (31 a.C.), de la cual emerge vencedor el primero, erigiéndose en el único gobernante de Roma, con la sumatoria de todos los poderes. Es el fin del período republicano.

Sin embargo, el proceso de descomposición del sistema comienza, como he dicho, con la siempre vigente lucha de clases. Si bien aparentemente la dualidad "patricia-plebeya" es históricamente superada mediante la equiparación de ambas, no se concreta realmente, por cuanto los ciudadanos originariamente patricios emergen en una nueva clase social denominada "óptimos", la cual cobija a quienes tienen una ascendencia patricia, senatorial y acaudalada. En el polo opuesto se encuentran situados los "populares", que no poseen bienes ni poder político, pero que en cambio resultan mayoría y prestan, por lo general, aporte sustancial al Estado y al ejército. Los hermanos

Graco son víctimas fagocitadas por el poder e influencia de la clase más poderosa. Esta sórdida lucha de clases se mantiene durante los últimos cien años del sistema republicano, con la irrupción en la escena política de los "caudillos militares" Mario y Sylva. La presencia rutilante del gran Julio César preanuncia el sistema imperial, pero es asesinado por contrariar los intereses de los "óptimos", así como anteriormente hicieron con los hermanos Graco. Habrá de ponerse particular atención en cuanto a que el nuevo sistema denominado "Alto Imperio", "Principado", también se conoce como "Gobierno de las Dos Cabezas" o "Diarquía", es decir, "Príncipe y Senado"⁽⁴⁴⁾. La lucha social instalada en la república eclosiona con la victoria de la clase más poderosa, cuyo reservatorio es siempre el Senado, partícipe necesario y fundamental del nuevo modo de gobierno.

También desde otro punto de vista he de destacar que el sistema republicano deja de brindar respuestas concretas a los puntuales problemas que se presentan en el mundo romano. La presencia e injerencia del ejército lentamente se torna cada vez más poderosa, y no en vano sus conductores se erigen en los hombres fuertes del gobierno, v.gr., Mario, Sylva, Pompeyo y César. Debo destacar que el ejército paulatinamente comienza a tomar mayor injerencia en los asuntos del Estado romano, hasta convertirse en un "verdadero e insoslayable factor de poder y decisión". Por dicha razón he variando mi opinión al respecto últimamente, inclinándome por considerar que se encuentra un tanto superada la denominación de "Diarquía" como sinónimo de "Alto Imperio", dado que, si bien la encontramos configurada en tiempos de Augusto, luego, especialmente ante la creación de la Guardia Pretoriana por parte de éste, la presión y poderío castrense se intensifican de tal modo que la cuestión política asemeja descansar en un "trípode" compuesto por Príncipe, Senado y Ejército.

Por lo demás, la parálisis institucional se hace más frecuente y alarmante, siendo la característica de gobierno "la inercia", debiéndose buscar soluciones mediante el recurso constitucional de nombrar "dictadores". Justamente en los poderes de esta magistratura extraordinaria descansa la base política de la figura del Príncipe, devenido entonces en una "supermagistratura ordinaria". A este respecto debo destacar que la tan mentada "practicidad romana en el ámbito jurídico" también se advierte en "el campo político". Los romanos son esencialmente realistas y hallan la solución a la "crisis republicana de gobierno" dentro del mismo sistema que saben fenecido, lo que en verdad constituye un gran mérito.

FRANJA
MORADA

Capítulo V - Período Imperial

CAPÍTULO V - PERÍODO IMPERIAL

I. EL NACIMIENTO DEL IMPERIO. AUGUSTO(1)

Las particulares características del nuevo sistema de gobierno distan del anterior. La pluralidad del ejercicio del poder que caracteriza a la República distribuido en magistraturas, Senado y comicios, acotada por controles mutuos con la finalidad de evitar el ejercicio del poder absoluto, lentamente pertenece al pasado. El poder político es ejercido de modo autoritario únicamente por el Príncipe, sustentado por el ejército, y apoyado por el Senado, del cual el primero forma parte. La lectura de los acontecimientos permite aseverar que esta nueva forma de gobierno absorbe todo el poder político, languideciendo paulatinamente las viejas magistraturas republicanas y los comicios. El Príncipe ejerce el poder apuntalado por el poder castrense, y si no está en condiciones de gobernar por ineptitud, incapacidad, etc. (v.gr., Calígula, Claudio, Nerón, etc.), el Senado, junto con la Guardia Pretoriana, dirige los asuntos del Estado. He aquí la respuesta al esplendor y expansión que Roma logra en este período, aun con la presencia, en muchos casos, de príncipes no aptos para el gobierno. El Senado los sostiene en el gobierno junto con la Guardia Pretoriana, manteniendo la política y coherencia del Estado romano.

También otra lectura más profunda del tema indica que el verdadero ejercicio del poder está en manos de la clase más adinerada e influyente, que si bien ha cambiado de nombre, sigue firme en el Senado, rigiendo los destinos de Roma y de sus propios intereses. Un rol más que relevante tiene en esta época de cambio Octavio, heredero de César, vencedor de Marco Antonio en la batalla de Actium, que es considerado el primer Príncipe, el iniciador del nuevo sistema imperial que conduce la transición hacia un nuevo sistema de gobierno. Durante su largo mandato (27 a.C. a 14 d.C.), tiene la virtud de apaciguar los temores emergentes del fin del período republicano, simulando gobernar para restaurarlo, cuando en realidad configura un nuevo sistema, acentuando y consolidando el poder en sus manos y en las del Senado.

Conocido como Octavio, su nombre completo es Cayo Julio César Octaviano, aunque durante su gobierno se lo llama César Augusto, o simplemente Augusto. Es hábil político y gobernante, sabe interpretar correctamente la realidad de la época que le toca en turno vivir. Capitaliza la experiencia política producida por el asesinato del "divino" Cayo Julio César, intuyendo que éste había avizorado un nuevo sistema y que incluso es el primero en ejercerlo, pero que además ha afectado, sin advertirlo, el poder de los grandes intereses del poder enquistado en los "óptimos", quienes deciden su muerte. Por tal motivo gobierna prudentemente, apaciguando las aguas mientras fortalece su poder, delineando, quizá sin saberlo, una nueva magistratura, el Principado, superior a las republicanas, que luego son absorbidas por aquella. El secreto de su acción de gobierno es respetar el deseo de los gobernados de no querer ser regidos bajo un sistema de gobierno autoritario encarnado en una sola persona, evitando así los desmanes propios del poder absoluto, restaurando a tales efectos los órganos de gobierno de la República, mientras en verdad y por debajo les quita atribuciones de poder, acentuando el suyo y el del Senado, creando una nueva estructura. Lo expuesto se puede resumir en pocas palabras: "Hace creer al pueblo que restaura el antiguo sistema republicano cuando en rigor de verdad inicia el imperio".

La acumulación del poder en manos de Augusto es paulatina pero constante. Recibe en principio por parte del Senado el título de *imperator* con carácter vitalicio. Luego, aquél confirma toda su actuación contra Marco Antonio y lo respalda públicamente, jurándole obediencia. Se lo nombra "padre de la patria" y *Princeps Senatus*. También se le otorga la "potestad tribunicia" (tribunicia potestas) y el "imperio proconsular" (imperio proconsulare) de modo independiente al tribunado y al consulado ordinarios, que coexisten junto al Príncipe, pero sujetos a éste. Es investido de la "púrpura imperial" que le brinda obediencia, dignidad y respeto. Es considerado hijo de "César divinizado" (divus Iulius), otorgándole un tinte religioso al poder de su mando. En síntesis, se advierte claramente que después de Augusto y la absorción de poderes en su persona por la magistratura que ostenta (Principado), Roma se encuentra regida por un nuevo sistema de gobierno, completamente distinto del anterior, dado que presenta características propias y autoritarias: el imperio. Arribado este punto, dejo en claro que el período imperial se divide en varias etapas diferenciadas el Alto Imperio (27 a.C. a 283 d.C.), el Bajo Imperio (284 a 526), el período justiniano (527 a 565), el período postjustiniano (566 a 1453).

Habría que destacar el brillante maniobrar político de Augusto, por cuanto, en su afán de darle a entender al pueblo que rigen las viejas estructuras republicanas, renuncia periódicamente a los poderes recibidos, haciendo entrega de éstos, los que inexorablemente le vuelven a ser conferidos hasta que el sistema se perpetúa. Sus descendientes comienzan a ejercer el Principado de manera autónoma y por derecho propio, sin necesidad de recibir cada vez los poderes del pueblo, aunque por cierto tiempo se mantiene el procedimiento como método tradicional más que por necesidad.

II. LA ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ALTO IMPERIO

El estudio de la organización constitucional del Alto Imperio permite analizar en principio las atribuciones y facultades de los dos excluyentes órganos de gobierno de este período, el Príncipe y el Senado, y después la aparición e injerencia temible del ejército en el poder. De modo paralelo se verá la supervivencia y evolución de las instituciones netamente republicanas dentro del nuevo sistema.

III. EL PRINCIPADO. NATURALEZA DE SU ORIGEN. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES⁽²⁾

Al profundizar el tema, es menester retomar la idea inicialmente esbozada cuando he tratado las causas del "fin del período republicano". En dicha oportunidad he sostenido que los romanos no sólo son prácticos y realistas en el aspecto jurídico, sino también en el político. Sostengo esta tesis por cuanto, adentrando en el complejo pensamiento institucional romano, arribo a la conclusión de "que es un pueblo que jamás desecha la experiencia adquirida", siempre que crea una institución elabora su evolución, no permitiendo que perezca en el transcurso del tiempo, sino adecuándola a las distintas necesidades que se presentan. Es el caso del Principado.

Institucionalmente, el Príncipe es la cabeza del Senado, es el primero de los senadores quien lo preside. Retrocediendo en el tiempo, advierto que la figura del "Príncipe del Senado" tiene origen en la Monarquía, pero, claro está, con otra denominación y funciones. El "senado monárquico" cobija en su seno al interrex que reemplaza al rex en caso de acefalía. Este cargo honorífico de "senador más antiguo" se mantiene en la República bajo la denominación de "Príncipe del Senado", el cual lo preside, siendo el primero entre los senadores en dar opinión y voto, con la gran importancia política que esto implica. Es decir que a los politólogos y juristas romanos les resulta natural apuntalar y fortalecer la añeja figura del "Príncipe del Senado" (Princeps Senatus), que reviste Augusto, con la sumatoria de todos los poderes necesarios para que ejerza el gobierno sin tropiezos junto con el Senado, reemplazando lentamente las magistraturas republicanas. Esto acontece mediante la selección de las mejores atribuciones de estas últimas, esencialmente las consideradas mayores, y su concesión al Príncipe.

Se advierte, entonces, que el "Príncipe del Senado" no aparece institucionalmente como algo nuevo en el período imperial, sino como culminación evolutiva de la antigua dignidad patricia que tiene origen en el Senado de la época monárquica y luego se desarrolla durante la República. Esta institución es dotada con las mejores atribuciones emergentes de los magistrados republicanos. Del censor toma la "tacha censoria"; del tribuno, el "poder de veto" y "la inviolabilidad"; del pretor, la auctoritas a través del ejercicio del ius edicendi; del cónsul, "el poder de mandar y ser obedecido".

Por ende, el Príncipe goza de las siguientes atribuciones y prerrogativas, a saber: imperium consular y proconsular, potestad tribunicia y censoria, auctoritas y "pontificado máximo", que lo erigen en una magistratura superior y autónoma, encastrada sobre el viejo sistema republicano.

El imperium consular y proconsular le confiere el gobierno absoluto sobre las provincias que se encuentran bajo la hegemonía del Senado y el pueblo romano; el control del gobierno de las provincias senatoriales y su facultad de intervención, de ser necesario; el mando de todos los ejércitos, ya sea que estuviesen en la Península Itálica o en las provincias, y la designación de sus

jefes; disponer de las tierras públicas; fundar colonias; conceder la ciudadanía e impartir justicia con jurisdicción civil y penal.

La "potestad tribunicia" lo inviste de inviolabilidad respecto de su persona; del poder de vetar las decisiones emanadas de los otros órganos de gobierno; la prerrogativa de convocar el Senado y los concilios de la plebe, sometiéndoles la consideración de propuestas.

La "potestad censoria" le otorga la facultad de ordenar y supervisar los censos, la aplicación de la "tacha censoria" y el poder de elegir y controlar los miembros del Senado.

La auctoritas le permite asistir a los otros órganos de gobierno, tutelando los intereses del Estado. Por ella puede dirigir la política exterior del Estado; declarar la guerra y concertar la paz; designar candidatos para las magistraturas; dictar ordenanzas de carácter general y particular (constituciones), legislando en las provincias, colonias y municipios; acuñar moneda; exceptuar a los ciudadanos, según su voluntad, de todo aquello ordenado por las leyes.

El "pontificado máximo" le concede la vigilancia sobre los asuntos religiosos, y la decisión respecto de los candidatos a cubrir los cargos sacerdotales.

El Príncipe (Princeps) recibe también otras denominaciones honoríficas que traslucen su importancia y dignidad, v.gr., Imperator, César Augusto, Padre de la Patria, etc.

IV. EL SENADO(3)

Durante este período, consiste en la asamblea representativa de la clase más influyente y poderosa denominada "óptima", descendiente del antiguo "patriciado romano". Este cuerpo colegiado tiene la virtud de manipular la política de Roma, privilegiando sus intereses por sobre la clase "popular", constituyendo un factor de gran poder e intriga permanente.

El Príncipe, integrante natural del Senado, lo preside y tiene derecho a convocarlo. Julio César eleva su número a novecientos miembros; Marco Antonio a mil, y Augusto, luego, lo reduce a seiscientos. El Senado tiene el gobierno directo de un determinado número de provincias, elige a sus gobernantes y legisla en aquéllas. Por lo general, las provincias senatoriales son aquellas "pacificadas", consideradas "no conflictivas", ubicadas geográficamente en la parte central del imperio, con un menor número de tropas acantonadas dentro de sus límites. Estas provincias se cuentan como las más romanizadas por su proximidad a la capital y por ser las primeras en ser conquistadas. También el Senado fija y percibe dentro de las provincias sujetas a su mando los impuestos. Éstos son de dos tipos, a saber, el "tributo" (tributum), que ingresa directamente al Fisco del Príncipe (fiscus) y que es administrado a su arbitrio; y el "estipendio" (stipendium), que ingresa en el erario provincial (aerarium), que es administrado por el Senado.

El Príncipe, más tarde, le concede al Senado "el derecho de dictar resoluciones con fuerza de ley", denominado "senadoconsulto" (senatusconsultum), que consisten originalmente en meras invitaciones dirigidas a los magistrados para que apliquen determinadas normas jurídicas, naciendo así gradualmente una nueva fuente de producción de derecho.

Es de destacar que la actividad y protagonismo del Senado se advierte al inicio del nuevo sistema de gobierno, mas luego empalidece al promediar el período ante la cada vez más vigorosa absorción del poder por parte del Príncipe y la presencia inquietante del ejército. Entonces, lo que comienza para el Senado siendo un rol de participación activa y de peso en el gobierno de Roma, deviene en intrigas palaciegas junto a los jefes de turno de la "Guardia Pretoriana", obsesionados por usurpar el poder. Lo que de otro modo no dista del origen mismo del Senado cuando los "óptimos" obtienen la supremacía sobre los "populares", gobernando junto al Príncipe. Es decir, que si bien el Senado deja de tener participación directa en el gobierno ante la acumulación del poder del Príncipe, pasa a tenerlo de modo indirecto mediante influencia política. En definitiva, son distintas facetas de una misma problemática: el ejercicio del poder.

El comicio es la asamblea deliberativa por excelencia del pueblo romano, donde la clase "popular" mantiene fundamentalmente el control y protagonismo. Augusto utiliza políticamente la fuerza de su estructura para someter el tratamiento de "leyes rogadas" muy importantes. De tal modo, en el año 18 a.C. consigue que se dicte la ley que castiga severamente los delitos de adulterio y estupro (lex Iulia de Adulteriis Coercendis); la que regula el matrimonio (lex Iulia de Maritandis Ordinibus), y la que protege la dote de la mujer, prohibiendo al esposo gravarla o venderla bajo pena de nulidad (lex Iulia de Fundo Dotali). Un año después (año 17 a.C.) se dicta la ley por la que se pone en vigencia el "Procedimiento Formulario" en reemplazo del "Procedimiento de las Acciones de la Ley", que regula, además, el funcionamiento del "Tribunal de los Centunviros" (lex Iulia de Iudiciorum Publicorum et Privatorum). En el año 8 a.C. se dictan las leyes que reprimen la compra de votos electorales para la elección de magistrados (lex Iulia de Ambitu); la que castiga el hurto de cosas públicas (lex Iulia de Peculatus); la que sanciona la violencia cometida con o sin armas de un individuo hacia otro (lex Iulia de vi publica vel privata); y la que castiga los atentados cometidos contra el Príncipe (lex Iulia de Maiestatis).

Más tarde, ya en nuestra era (año 2), se roga la que prohíbe la manumisión testamentaria que exceda un determinado número de esclavos (lex Fufia Caninia, propuesta por los cónsules C. Fufius Geminus y L. Caninius Gallus). En el año 4 se dicta la ley que limita las manumisiones de esclavos y regula sobre la libertad concedida a éstos (lex Aelia Sentia de Manumissionibus, dictada a propuesta de los cónsules Sexto Elio y Cayo Sentio, siguiendo directivas de Augusto). También son consideradas de esta época las leyes que norman sobre los póstumos (lex Iulia Velleia) y la que impone un impuesto sobre la sucesión de un pariente lejano (lex Iulia de Vicesima Hereditatum).

Aproximadamente entre los años 7 y 21, aunque se discute en rigor de verdad si es una idea de Julio César (tomada entre los años 49 y 44 a.C.), se dicta la ley que reglamenta el funcionamiento de las personas de existencia ideal y la autorización del Estado al respecto (lex Iulia de colegiis)⁽⁵⁾.

En el año 9 se sanciona la ley que establece una situación de privilegio para los que estuviesen casados, o además tuviesen hijos, gravando e imponiendo restricciones hereditarias para los que se mantengan solteros o casados sin hijos, dando lugar a lo que se llama "la legislación matrimonial de Augusto", conocida también como "leyes caducarias" (lex Iulia et Papia Poppaea, propuesta a ruego por los cónsules Papius Mutilus y C. Pappaeus Sabinus, que cristalizan directivas expresas de Augusto en tal sentido⁽⁶⁾). Esta ley complementa la dictada precedentemente en la materia (lex Iulia de Maritandis Ordinibus).

Una vez finalizado el principado de Augusto y acentuada la absorción del poder por parte de los príncipes posteriores, los comicios comienzan inexorablemente a decaer. Una explicación puede encontrarse en la tan mentada "lucha de clases" y en la obtención de la supremacía por parte de los "óptimos". Recuérdese que el Senado representa a los primeros y los comicios a los "populares". El hecho circunstancial de que el primero, directa o indirectamente, mantenga el poder junto al Príncipe, representante natural de los "óptimos", demuestra la merma del poderío de los segundos.

La limitación de las atribuciones de los comicios comienza a tener lugar, en principio, cuando se les quitan las prerrogativas judiciales y electorales. En cuanto a las primeras, se dispone en materia criminal la creación de tribunales permanentes que reemplazan a los comicios en el tema, estableciendo además que en lo sucesivo las penas capitales son apeladas ante el Príncipe, perdiendo entonces la gran importancia que tienen los comicios en tal aspecto, puesto que cae completamente en desuso el "recurso popular" de la provocatio ad populum. Con respecto a las facultades electorales, éstas son prácticamente suprimidas cuando el Príncipe se arroga, primero, el derecho de imponer los nombres de los candidatos y, más tarde, delega tal facultad directamente al Senado.

Advierto que la última actividad de importancia de los comicios es en tiempo de Augusto, cuando se implementan las leyes indicadas ut supra. Luego, lentamente, comienzan a languidecer. Aun así todavía encuentro vestigios de la labor comicial entre los años 19 y 24, durante el gobierno de Tiberio, mediante las leyes rogadas que reglamentan el régimen de manumisiones, limitándolas y prohibiendo la ciudadanía romana para determinados libertos (lex Iulia Norbana), y la ley que castiga la usurpación de la ingenuidad y del decurionato a los efectos de la ciudadanía, favoreciendo a los latinos para adquirirla (lex Visellia). Después, en tiempos de Claudio (año 42), se roga la ley que rige las tutelas (lex Claudia). En el año 61, bajo el poder de Nerón, se dicta la ley que prohíbe al esposo que desista de la acusación de adulterio contra su esposa ejercitarla nuevamente (lex Petronia, a pedido del cónsul Petronius Turpillianus). Poco después, en el año 70, se dicta la ley que concede la autoridad imperial a Vespasiano (lex de Imperio Vespasiani). De aquí en más, prácticamente la actividad de los comicios es inerte hasta el dictado de una última ley, en tiempos de Caracalla, también considerada por otros como Constitución, por la que se le concede en el año 212 la ciudadanía a todos los habitantes del imperio (lex Antoniana). Finalmente, a partir del año 300 puedo, afirmar que los comicios desaparecen por completo.

VI. EVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS MAGISTRATURAS REPUBLICANAS(7)

Es interesante seguir el desarrollo de las magistraturas republicanas durante el Alto Imperio. En un principio, éstas no desaparecen por completo, sino que, por el contrario, subsisten un largo tiempo dentro del nuevo sistema imperial, pero con facultades disminuidas y acotadas, absorbidas por el Príncipe y los nuevos funcionarios rentados creados por éste. Luego, lentamente, promediando el Alto Imperio, comienzan a ser abolidas por el Príncipe, o simplemente desaparecen con el transcurso del tiempo.

1. Consulado

Es la magistratura que más padece la pérdida de poder e importancia al asumir el Príncipe un rol preponderante. Esto es así por cuanto el Príncipe se arroga la facultad de dirigir la política exterior del Estado; el mando de los ejércitos; el gobierno de las provincias y el erario público. Los cónsules rescatan la atribución de presidir los comicios y el Senado en ausencia del Príncipe, o si éste lo consiente; y de actuar judicialmente en materia criminal y en asuntos de manumisiones, adopciones y alimentos. Incluso, deja de ser una magistratura anual para convertirse en semestral, luego en cuatrimestral y finalmente en bimestral.

2. Pretura

El nuevo sistema le resta su atribución más importante cuando se faculta al Príncipe a intervenir en la etapa previa al juicio (iudicio), creando derecho. Igual sobrevive en la estructura estatal, tanto como pretor urbano y peregrino, manteniendo la jurisdicción en materia civil en Roma y en el resto de Italia. Recibe un duro golpe en el año 131, cuando Adriano pone en vigencia el "Edicto Perpetuo", encomendado al jurista Salvio Juliano que recopile toda la actividad de los pretores hasta dicho momento. Adriano reserva para el Príncipe la facultad de ser el único que pueda completarlo o modificarlo, vedando así definitivamente a la Pretura su facultad más importante: crear derecho. Continúa manteniendo función jurisdiccional en materia de fideicomisos, tutela y libertad, actuando en los pleitos entre el Fisco y particulares, presidiendo el tribunal de los centunviro (centunviri). Con la disposición tomada por Caracalla en el año 212, por medio de la cual se le concede la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, es abolida "la pretura peregrina", mientras que la "urbana" persiste, prestando funciones hasta el gobierno de Diocleciano.

3. Censura

Pierde sus prerrogativas e importancia, puesto que se le cercena la facultad de aplicar la "tacha censoria", de confeccionar la lista senatorial (lectus senatus) y de realizar el censo. Estas funciones son trasladadas a un nuevo funcionario creado en el Imperio, el praefectus morum, que trabaja junto al Príncipe y depende únicamente de su persona. El censor sólo conserva la función de redactar un listado de los ciudadanos y ejercer la coordinación de los "censos municipales" llevados a cabo por los funcionarios locales. La magistratura desaparece en tiempos de Domiciano.

4. Tribunado de la plebe

El Príncipe le asesta un golpe de muerte cuando asume sus facultades esenciales para fortalecer su propia investidura. Así, pierde la atribución de "vetar las decisiones de los magistrados republicanos" (*intercessio*) y de convocar a los concilios de la plebe (*ius agendi cum plebe*). Sólo conserva el derecho de vetar "decisiones de carácter menor tomadas por los magistrados que tienen jurisdicción en material civil". Augusto le añade ciertas funciones nuevas y de poca significancia para justificar su existencia, como supervisar las nuevas circunscripciones de la ciudad creadas por él, y la inspección de las sepulturas. El tribunado es suprimido en la época de los Severos.

5. Cuestura

En el nuevo sistema de gobierno la cuestura pierde sus facultades de controlar el erario público (*aerarium*) y de participar en la sustanciación de los procesos capitales. Sin embargo, se le confía la organización de los juegos de gladiadores. Si bien no desaparece como magistratura, pierde autonomía, convirtiéndose en un simple colaborador y depende directamente del Príncipe, gobernador de provincia o magistrado de grado superior.

6. Edilidad curul

En la nueva reforma dispuesta por el Príncipe se le cercenan sus facultades, transfiriéndoselas a los nuevos funcionarios imperiales. De tal modo, pierde las funciones de policía en los mercados en cuanto a vigilancia de precios y condiciones de las mercaderías, esclavos y animales (*cura annonae*), que es absorbida por el nuevo *praefectus annonae*. Conserva la atribución de contralor de los espectáculos públicos (*cura laudorum*), pero no de manera exclusiva y autónoma, dado que debe llevarlo a cabo con la supervisión de los pretores y tribunos. En cuanto a las facultades dirigidas al cuidado de la ciudad, conservación edilicia, ornato, habitabilidad, servicio de extinción de incendios y policía nocturna (*cura urbis*), sólo conserva simples funciones de policía en las vías urbanas, perdiendo todas las demás.

VII. LOS NUEVOS FUNCIONARIOS CREADOS POR EL PRÍNCIPE⁽⁸⁾

El Alto Imperio se caracteriza también por la aparición de nuevos funcionarios creados por el Príncipe. Ellos se adaptan mejor a la nueva estructura piramidal impuesta a partir de Augusto y acentuada por sus sucesores. La burocracia, en el sentido moderno de la palabra, se encuentra incipiente en tiempo de Claudio. El Príncipe necesita colaboradores elegidos libremente por su persona, sin injerencia del Senado y los comicios, que dejan de ejercer el control sobre aquéllos en cuanto a su desempeño en el cargo. Por esta razón, los funcionarios imperiales no revisten el carácter de magistrados, ni tampoco tienen autoridad propia. Permanecen en el cargo hasta tanto fuese el deseo del Príncipe, quien los escoge a su arbitrio entre la clase de los "óptimos" y a quien sólo le rinden cuenta de sus actos recibiendo una remuneración por su función.

Los más importantes y destacados funcionarios de la época imperial son los siguientes: *praefectis praetorio*; *praefectis urbi*; *praefectis vigilum*; *praefectis annonae*; *praefectis aerari*; y *praefectis Aegypti*.

1. Prefecto del pretorio (praefectus praetorio)(9)

Es el jefe de la guardia personal del Príncipe. Esta última es un cuerpo especial del ejército (pretorio) creado por Augusto, preocupado por la falta de una tropa estable en Roma, destinada a velar por la seguridad personal del Príncipe. Esta decisión, adoptada en principio con buen tino por Augusto, resulta luego nefasta por la gran injerencia y poder que concentra en sus manos, en especial su jefe, el prefecto, ya que explota en beneficio de sus propios intereses la responsabilidad que descansa en sus manos. Esto se traduce en que los jefes de la guardia pretoriana se encargan de asesinar y reemplazar a su antojo a los Príncipes, convirtiéndose en un verdadero e insoslayable factor de poder dentro del imperio. Muchas veces, la meta del futuro jefe del pretorio es obtener la confianza del Príncipe para que éste lo designe en el cargo, y luego disponer su asesinato para que lo nombren en su lugar. Esta corruptela decide más tarde, en el año 284, a Diocleciano ordenar la disolución de la citada guardia pretoriana para salvaguardar verdaderamente la integridad del Príncipe.

He referido ut supra que el poder concentrado por el ejército, ya sea a través de la guardia pretoriana o las tropas regulares, debe interpretarse como un "factor de poder", dado que junto a las instituciones del Príncipe y el Senado conduce el imperio. Si bien estos últimos son los órganos constitucionales de gobierno, el ejército, por la importancia que adquiere, no puede ser soslayado en el orden constitucional, erigiéndose en un tercer órgano de gobierno, aunque de un modo no explícito. Esta situación me ha llevado a repensar, como lo dijera oportunamente, que el Alto Imperio deja pronto de ser una diarquía para ser triarquía. No obstante la reflexión expuesta, destaco que se dota al prefecto del pretorio de facultades judiciales. Como consecuencia de esto, entiende en grado de alzada respecto de las apelaciones de sentencias criminales y civiles dictadas por los gobernadores de provincia; ejerce jurisdicción criminal en Italia, con excepción de Roma, hasta un radio de cien millas a la redonda.

Lo dicho me lleva a efectuar la siguiente consideración: el cargo de jefe del pretorio, con sus prerrogativas militares y judiciales, es creado por un excelente propósito. El hecho de que determinados líderes militares empañasen el cargo no la invalida como función. La prueba radica que la calidad de persona, en realidad, hace al cargo. Esto significa que cuando son designados jefes de la guardia pretoriana personas probas, el Príncipe está bien resguardado, y las funciones de vigilancia y justicia se cumplen. Los casos notorios que convalidan lo expuesto son Papiniano, Paulo y Ulpiano, grandes juristas designados jefes del pretorio, quienes se dedican verdaderamente a crear derecho y velar por la salud del Príncipe.

2. Prefecto urbano (praefectus urbis)(10)

Tiene atribuciones sobre el cuidado de la ciudad, ejerciendo el poder de policía a través de la tropa que se encuentra a su mando (las tres cohortes urbanas). También es el encargado de la persecución de los cultos prohibidos por el Príncipe, la vigilancia de los mercados y la jurisdicción criminal dentro de la ciudad de Roma, pudiendo aplicar penas, incluso hasta la deportación.

3. Prefecto de vigilancia (praefectus vigilum) (11)

Ejerce la jefatura de la guardia especial nocturna destinada a prevenir los robos e incendios dentro de la ciudad, con facultad de castigar tales delitos. Las siete cohortes bajo su mando destinadas a tales efectos reciben la denominación de "vigilantes" (vigiles).

4. Prefecto de aprovisionamiento (praefectus annonae)